

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ



БИЛТЕН

1



intermex
Software & Communications

Ниш, 2013. године

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

БИЛТЕН

Бр. 1



Ниш, 2013. године

БИЛТЕН

АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ

ИЗДАВАЧ: Intermex, Београд, Булевар војводе Мишића 37/II
За издавача: Љиљана Миланковић-Васовић, директор

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ
УРЕДНИК:

Драган Јоцић,
в.ф. председника Апелационог суда у Нишу

ЗАМЕНИК
ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ
УРЕДНИКА:

Слађана Ђуричковић,
судија Апелационог суда у Нишу

РЕДАКЦИЈСКЕ ГРУПЕ

За кривично право: судија Снежана Милошевић - руководилац групе
судија Мирјана Ђорђевић - члан

За грађанско право: судија Слађана Ђуричковић - руководилац групе
судија Мирослава Миловановић - члан
судија Ивана Рађеновић - члан

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: Златица Петровић, судијски помоћник

ШТАМПАРИЈА: "DIS Public", Београд

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
34

БИЛТЕН Апелационог суда у Нишу / главни и одговорни уредник Новица Стефановић. - бр. 1, 2013- . - Београд (Булевар војводе Мишића 37/II) : Intermex, 2013- (Београд : "DIS Public"). - 22 cm

Три пута годишње. - Је наставак: Билтен судске праксе - Окружни суд у Нишу = ISSN 1452-6603
ISSN 2217-4125 = Билтен Апелационог суда у Нишу - COBISS.SR-ID 179852044

Свако копирање, умножавање, објављивање и дистрибуирање целине или делова текста из ове публикације представља повреду ауторског права и кривично дело (сходно одредбама чл. 215.-217. Закона о ауторском и сродним правима, и чл. 198.-202. Кривичног законика).

Коришћење делова текста из овог Билтена дозвољено је сходно ауторском праву и уз сагласност издавача.

САДРЖАЈ

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ ЗА 2013. ГОДИНУ	5
---	---

ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ ЗА 2013. ГОДИНУ	11
--	----

УПОРЕДНИ ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ	12
---	----

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА

Драган Јоцић

Забрана ублажавања казне	19
--------------------------------	----

СУДСКА ПРАКСА

КРИВИЧНО ПРАВО	31
-----------------------------	----

Кривично материјално право	33
----------------------------------	----

Кривично процесно право.....	50
------------------------------	----

ГРАЂАНСКО ПРАВО	67
------------------------------	----

Процесно право	69
----------------------	----

Облигациони односи	74
--------------------------	----

Стварно право	87
---------------------	----

Породично право	92
-----------------------	----

Наследно право	97
----------------------	----

Радно право	102
-------------------	-----

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ ЗА 2013. ГОДИНУ

I

СУДСКА УПРАВА

Пословима судске управе руководи председник суда.

За заменика председника суда одређује се судија Братислав Крстић.

Заменику председника суда, поред општих послова, поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то:

1. доношење и потписивање аката судске управе у одсуству председника суда, а које нису у искључивој – непреносивој надлежности председника суда;
2. поступање по притужбама и захтевима за изузеће судија;
3. поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
4. спровођење и праћење Програма решавања старих предмета.

Посебне обавезе поверавају се судији Снежани Милошевић за информисање и контакте с јавношћу и медијима (портпарол).

II

СУДСКА ОДЕЉЕЊА

За председнике судских одељења одређују се и то:

1. У Одељењу судске праксе: председник Новица Стефановић, вршилац функције председника суда; заменици судија Вера Милошевић, Мирослава Миловановић и судија Зоран Ђорђевић.

2. У Кривичном одељењу: председник, судија Снежана Милошевић, а заменик судија Зоран Поповић.

3. У Грађанском одељењу: председник, судија Слађана Ђуричковић, заменик судија Миомир Митровић.

4. У Одељењу радних спорова: председник судија Зоран Ђорђевић, заменик судија Ивана Рађеновић.

III

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1.

I – ВЕЋЕ

1. Вера Милошевић, председник већа,

2. Љиљана Миљковић, члан,

3. Ранко Банковић, члан

Судијски помоћници:

- Ивана Лазовић и Милан Ђорђевић

II – ВЕЋЕ

1. Братислав Крстић, председник већа,

2. Весна Стевановић, члан

3. Драгана Живадиновић, члан

Судијски помоћници:

- Ана Јовичић, Милица Алексић и Зоран Ђурђевић

Ово веће ће примати предмете у поступцима према малолетницима, те ће чинити и веће за малолетнике.

III – ВЕЋЕ

1. Снежана Милошевић, председник већа,
2. Слободан Љубић, члан
3. Љубомир Јовановић, члан

Судијски помоћници:

- Милош Увалин, Марија Петровић, Ненад Стојановић

IV – ВЕЋЕ

1. Зоран Поповић, председник већа,
2. Мирјана Ђорђевић, члан
3. Слободан Стојилковић, члан

Судијски помоћници:

- Иван Калезић, Ивана Милошевић и Владимир Станојевић

V – ВЕЋЕ

1. Новица Стефановић, председник већа,
2. Горана Митић, члан,
3. Небојша Цолић, члан

Судијски помоћници:

- Слађана Лендра

Веће за одлучивање у трећем степену биће у сваком конкретном предмету одређено посебном наредбом председника суда.

2.

Председника већа замењује први члан већа.

Попуна већа до пуног састава вршиће се према посебном распореду који ће месечно утврђивати председник Кривичног одељења.

Дежурна већа за време годишњих одмора у Кривичном одељењу:

- у јулу месецу III веће,
- у августу месецу IV веће

IV

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

I – ВЕЋЕ

1. Слађана Ђуричковић, председник већа,
2. Љиљана Јовановић, члан,
3. Миомир Митровић, члан

Судијски помоћници:

- Бети Лазаревић, Јелена Божиловић и Сандра Стефановић

II – ВЕЋЕ

1. Мирослава Миловановић, председник већа,
2. Данијела Николић, члан,
3. Слободанка Китановић, члан

Судијски помоћници:

- Милена Симоновић, Миљана Поповић Ђурић и Мирјана Милутиновић

Судије I и II већа примаће и предмете у вези породичних и статусних спорова, те ће чинити посебна већа за наведене спорове.

III – ВЕЋЕ

1. Миодраг Марјановић, председник већа,
2. Марина Милановић, члан
3. Александар Пантић, члан,
4. Јасмина Андрејевић, члан

Судијски помоћници:

- Јелена Јанчетовић, Јелена Увалин, Јелена Голубовић и Горан Драгоман

V

ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

IV – ВЕЋЕ

1. Зоран Ђорђевић, председник већа,
2. Весна Вукас, члан
3. Тања Ристић, члан

Судијски помоћници:

- Драгана Вељковић и Весна Јовановић-Јанковић

V – ВЕЋЕ

1. Јелена Јовановић, председник већа
2. Милица Манић, члан
3. Зорица Цветковић, члан

Судијски помоћници:

- Ивана Ђурђић Митровић и Јелена Станковић

VI – ВЕЋЕ

1. Ивана Рађеновић, председник већа,
2. Љубиша Милојевић, члан
3. Слађана Стојановић, члан

Судијски помоћници:

- Слађанка Тасић, Слађана Љубеновић и Наташа Митковић

VI

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Одељење судске праксе чине судије:

1. Новица Стефановић, вршилац функције председника суда,
2. Снежана Милошевић, председник Кривичног одељења,
3. Слађана Ђуричковић, председник Грађанског одељења,
4. Зоран Ђорђевић, председник Одељења радних спорова,
5. Вера Милошевић, руководиоца евиденције судске праксе у Кривичном одељењу,
6. Мирослава Миловановић, руководиоца евиденције судске праксе у Грађанском одељењу,
7. Судијски помоћник Горан Димитријевић у Кривичном одељењу, кога мења судијски помоћник Ненад Стојановић,
8. Судијски помоћник Златица Петровић у Грађанском одељењу, коју мења судијски помоћник Јелена Станковић,

ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ ЗА 2013. ГОДИНУ

Годишњи распоред послова судија Апелационог суда у Нишу Су I-2-12/12 од 03.12.2012. године мења се и то:

У делу става I Судске управе, уместо „Пословима судске управе руководи председник суда“, сада гласи „Пословима судске управе руководи Вршилац функције председника суда“.

У делу става II Судска одељења, уместо „У Одељењу судске праксе: председник суда Новица Стефановић“, сада гласи „У Одељењу судске праксе: Вршилац функције председника суда Драган Јоцић“.

У делу става V – ВЕЋЕ, уместо „1. Новица Стефановић, председник већа“ сада гласи „Драган Јоцић, председник већа“.

У делу става III Кривично одељење, иза наслова V – ВЕЋЕ, додаје се „Формира се веће за решавање искључиво старих предмета у саставу:

1. Драган Јоцић, председник већа,
2. Братислав Крстић, члан
3. Снежана Милошевић, члан

Члана већа чиниће судија који реферише своје предмете. Ово веће се не задужује предметима.

У делу става IV Грађанско одељење, на крају овог става се додаје: „Председника већа замењује први члан већа, а попуна већа вршиће се из реда чланова наредног већа Грађанског одељења“.

У делу става V Одељење радних спорова, на крају овог става се додаје: „Председника већа замењује први члан већа, а попуна већа вршиће се из реда чланова наредног већа Одељења за радне спорове“.

УПОРЕДНИ ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПРЕДМЕТА

МАТЕРИЈА	2010	2011	2012	2013
КЖ1	2594	2002	2391	2079
КЖ2	658	632	808	962
КЖ3	3	3	13	5
КР	29	35	32	41
КЖМ1	12	26	34	41
КЖМ2	17	7	6	9
КРМ	3	3	2	4
ГЖ	3508	1352	1431	1335
ГЖ1	1957	1380	1128	1665
ГЖ2	184	200	170	195
ГЖ3	0	0	1	2
Р	5	24	15	59
Р1	0	0	16	170
РЕХ	1	1	1	15
УКУПНО	8971	5665	6048	6582

БРОЈ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА

МАТЕРИЈА	2010	2011	2012	2013
КЖ1	935	1434	1845	2702
КЖ2	563	605	767	952
КЖ3	2	0	13	3

КР	26	34	33	38
КЖМ1	3	22	31	34
КЖМ2	15	7	7	9
КРМ	2	2	2	3
ГЖ	1890	1327	1533	1589
ГЖ1	998	1240	1362	1522
ГЖ2	170	182	158	184
ГЖ3	0	0	1	2
Р	5	26	14	57
Р1	0	0	12	157
РЕХ	1	1	1	13
УКУПНО	4610	4880	5779	7265

ПРОСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ

МАТЕРИЈА	2010	2011	2012	2013
КЖ1	12,96	18,38	23,65	34,64
КЖ2	8,50	7,76	9,83	12,21
КЖ3	0,11	0,00	0,17	0,13
КР	0,39	0,44	0,42	0,49
КЖМ1	0,17	0,92	1,29	2,83
КЖМ2	0,83	0,29	0,29	0,75
КРМ	0,11	0,08	0,08	0,25
ГЖ	31,50	15,80	21,29	26,48
ГЖ1	18,48	17,22	25,22	31,71
ГЖ2	4,72	5,06	4,39	5,11
ГЖ3	0,00	0,00	0,17	0,17

P	0,21	0,22	0,11	0,95
P1	0,00	0,00	0,22	3,27
PEX	0,17	0,01	0,01	0,22
УКУПНО	24,78	24,65	28,26	39,06

САВЛАДАВАЊЕ ПРИЛИВА

МАТЕРИЈА	2010	2011	2012	2013
КЖ1	36,02	71,63	77,16	129,97
КЖ2	85,65	95,73	94,93	98,96
КЖ3	66,67	0,00	100,00	60,00
КР	89,66	97,14	103,13	92,68
КЖМ1	25,00	84,82	91,18	82,93
КЖМ2	88,24	100,00	116,67	100,00
КРМ	66,67	66,67	100,00	75,00
ГЖ	53,88	98,15	62,47	119,03
ГЖ1	51,00	89,86	75,21	91,41
ГЖ2	92,39	91,00	89,27	94,36
ГЖ3	0,00	0,00	100,00	100,00
P	100,00	108,33	93,33	96,61
P1	0,00	0,00	75,00	92,35
PEX	100,00	100,00	100,00	86,67
УКУПНО	51,39	86,14	95,57	110,38

ПРОЦЕНАТ РЕШЕНИХ

МАТЕРИЈА	2010	2011	2012	2013
КЖ1	36,02	35,81	35,45	50,29
КЖ2	85,65	86,18	81,60	87,90
КЖ3	66,67	0,00	65,00	37,50
КР	89,66	91,89	94,29	90,48
КЖМ1	25,00	61,11	73,81	60,71
КЖМ2	88,24	87,50	100,00	100,00
КРМ	66,67	40,00	100,00	50,00
ГЖ	53,88	58,33	62,47	74,67
ГЖ1	51,00	55,56	75,21	70,92
ГЖ2	92,39	90,10	89,27	91,54
ГЖ3	0,00	0,00	100,00	100,00
Р	100,00	89,66	82,35	95,00
Р1	0,00	0,00	66,67	91,28
РЕХ	100,00	100,00	50,00	76,47
УКУПНО	51,39	51,17	53,87	64,27

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА

Драган Јоцић,

В.ф. председника Апелационог суда у Нишу

ЗАБРАНА УБЛАЖАВАЊА КАЗНЕ*

Законом о изменама и допунама кривичног законика (у даљем тексту ЗИД КЗ) објављеном у "Службеном гласнику РС", број 72 од 03.09.2009. године, примењује се од 11.09.2009. године, измењена је одредба члана 57. која одређује границе ублажавања казне. Одредбе садржане у ставу 1. тач. 1. и 2. су потпуно нове. Њима је ограничено овлашћење суда да учиниоцима кривичних дела, зависно од висине запрећене казне, исту ублаже испод границе прописане овим одредбама. У тачки 8. става 1. законодавац је прописао да се за кривична дела за која је прописана новчана казна, са назначењем најмање мере, казна може ублажити до десет дневних износа, док је у преосталом делу овај став остао непромењен.

Најзначајнија је, свакако, допуна одредбе члана 57. став 2. и став 3. али и измена става 4. ове одредбе због чега ће се разматрање и почети управо од одредбе садржане у ставу 2 па потом размотрити и остале измене и допуне.

Одредбом члана 57. став 2. ЗИД КЗ забрањено је суду да ублажи казне за кривична дела: отмице из чл. 134. ст. 2. и 3, силовања из чл. 178, обљубе над немоћним лицем из чл. 179, обљубе са дететом из чл. 180, изнуде из чл. 214. ст. 2. и 3, неовлашћене производње и стављања у промет опојних дрога из чл. 246. ст. 1. и 3, недозвољеног преласка државне границе и кријумчарења људи из чл. 350. ст. 3. и 4. и трговине људима из чл. 388. овог законика.

Ово ограничење не важи када је суд овлашћен да учиниоца ослободи од казне (ст. 4), односно суд учиниоцу, у том случају, казну може ублажити и за ова кривична дела применом чл. 57. ст. 1. КЗ.

Пошто је одредба потпуно нова, уметнута у општи део КЗ ваља размотрити у којој мери ремети КЗ у целини: и општи и посебни део КЗ али

* Рукопис је завршен пре усвајања „Маријиног“ закона.

и институте предвиђене Законом о кривичном поступку. У сваком случају кривична дела на која се примењује одредба чл. 57. ст. 2. су, управо овом одредбом, издвојена из читавог кривичноправног система.

Однос према другим одредбама општег дела КЗ

Већ је наведено да забрана садржана у ставу 2. члана 57. не важе уколико је суд овлашћен да учиниоца кривичног дела ослободи од казне, сагласно ставу 4. истог члана. Одредбе кривичних дела наведених у члану 57. став 2, у свом тексту, не предвиђају могућност ослобађења од казне учинилаца тих кривичних дела, тако да се та могућност мора потражити у другим одредбама општег дела КЗ.

Суд је, према одредбама општег дела КЗ, **овлашћен да учиниоца ослободи од казне** у случајевима прекорачења граница нужне одбране услед препаста изазване нападом (чл. 19. ст. 3), затим ако је учинилац прекорачио границе крајње нужде под нарочито олакшавајућим околностима (чл. 20. ст. 3), ако се ради о неподобном покушају (чл. 31) и у случају добровољног одустанка (чл. 32).

Подсетимо се да КЗ **не предвиђа могућност ослобађења од казне** када је кривично дело остало у покушају, ако је извршено под дејством силе која није била неодољива или под дејством претње (уопште), ако је извршено у стању битно смањене урачунљивости, ако је дело извршено у стварној или правној заблуди услед нехата. Такође ни у случајевима прекорачења граница нужне одбране или крајње нужде ако та прекорачења нису последица јаке препаста или раздражености изазване нападом.

Тако, код крајње нужде ако сила није била неодољива принуђени, односно окривљени, врши кривично дело ради избегавања зла које му прети, али му се казна не може ублажити јер вољни елеменат умишљаја ипак постоји.

Могућа је кумулација претходних института код окривљеног: да услед силе или претње окривљеном буде битно смањена урачунљивост али да зато што сила није била неодољива а урачунљивост није била искључена, казна не може бити ублажена. Или, учиниоцу код кога је утврђено постојање душевне болести, привремене душевне поремећености, заосталости у душевном развоју или теже душевне поремећености (као основа битно смањене урачунљивости) и према коме је примењена сила која

није апсолутна, или је због јаке раздражености или препасти, али не због напада, прекорачио границе нужне одбране, казна не може бити ублажена.

Искључена је и могућност ублажавања казне применом члана 58. КЗ јер се кривична дела побројана у члану 57. став 2. КЗ не могу извршити нехатно, нити је за њих запређена казна затвора до пет година. Исто важи и за, евентуалну, примену члана 59. КЗ.

Искључена је и примена члана 56. КЗ о ублажавању казне па самим тим и значај утврђивања постојања нарочито олакшавајућих околности, па тиме делимично и одредбе члана 54. КЗ односно општих правила о одмеравању казне, као и одредбе чл. 57. ст. 1. КЗ.

Посебно је проблематично изједначавање покушаног и свршеног кривичног дела. Кривично законодавство већ традиционално, и оправдано, прави разлику у кажњавању учиниоца зависно од тога да ли је својим радњама у потпуности остварио последицу кривичног дела или је она изостала. Сада уведено изједначавање тих ситуација је несумњиво дестимулативно за извршиоце тих дела, али и угрожавајуће по жртве тих дела. Предузимањем радњи које воде извршењу кривичног дела, иако дело није извршено, учинилац је већ у зони пуног кажњавања, као и за довршено кривично дело, што га стимулише да кривично дело доврши, јер остаје на истом. Тако, ако се жртва отмице да у бекство, извршилац више нема разлога да не настави да је гони, до потпуног извршења кривичног дела, уколико нема услова за добровољни одустанак.

Моргућа аргументација да извршиоци нису едуковани да праве разлику на коју се указује (покушаног и свршеног дела а односи се и на остале институте општег дела КЗ) нису прихватљиви, јер се тиме део нације квалификује као елементарно необразован. Уколико учиниоци и не праве наведену разлику, законодавац је мора правити.

Законодавац је очигледно овим кривичним делима дао посебан значај, издвајајући их од осталих кривичних дела, тиме наглашавајући њихову друштвену опасност и потребу не само појачане, већ и ванредне кривичноправне заштите друштва од учинилаца управо ових кривичних дела, односно неопходност њиховог оштријег кажњавања. Исти циљ законодавац је могао постићи већом запређеном казном за та дела, већим минимумом запређене казне, чиме би се сузила могућност примене члана 57. став 1. КЗ.

У сваком случају наведеним изменама судијама је знатно сужен значајан атрибут судијске власти: одлучивање о казни, овлашћење да казну уподоби околностима које утичу да казна буде већа или мања односно јачини угрожавања или повреде заштићеног добра и личним својствима учиниоца. Обим и значај ускраћивања ове судијске власти, осим начелне примедбе, произлази и из искуствено потврђене чињенице да су учесници у поступку и јавност најзаинтересованији за тај сегмент судског поступка, одлуку о казни.

Зато је основно питање зашто се законодавац одлучио да за само 8 кривичних дела и то за 4 од њих само за поједине облике извршења, искључи примену значајних института општег дела КЗ и на тај начин их промовише у „наткривична“ дела. Неодољиво се намеће одговор да је законодавац, неприхватањем да исти циљ оствари повећањем запрећених казни, управо желео да кривичноправни систем надогради, да уведе потпуно нов институт општег дела КЗ – забрану ублажавања казне.

Однос према одредбама посебног дела КЗ

Код кривичног дела **отмице** казна се не може ублажити ако је извршено кривично дело кажњиво по ст. 2. и 3. члана 134. КЗ али се може ублажити за кривична дела из ставова 1, 4. и 5. исте одредбе. Облици кривичног дела из ст. 4. и 5. су квалификовани облици кривичних дела из ставова 1, 2, и 3. ове одредбе и постоји када је код отетог лица услед извршења кривичних дела из ст.1. до 3. наступила смрт или ако их је извршила организована криминална група.

Одмах се уочава нелогичност да је забрањено ублажавање казне за облике кривичних дела из ст. 2. и 3. а да ван забране остану квалификовани облици овог кривичног дела. Тако долазимо до неприхватљиве ситуације са аспекта могућности изрицања најниже казне. Учиниоцу кривичног дела отмице који отетом само прети наношењем тешке телесне повреде и који своју претњу не оствари, нити отетог повреди, казна се не може ублажити и мора бити осуђен на казну затвора у трајању од најмање 3 године (став 2). Истом казном се мора осудити учинилац који је отето лице задржао дуже од 10 дана иако без икаквих последица по здравље отетог лица и без обзира што је према њему поступао крајње хумано.

Али на исту казну може бити осуђен и извршилац квалификованог облика овог дела, који је проузроковао смрт отетог лица или су извршиоци припадници организоване криминалне групе.

Дакле, учиниоцу чије су радње сведене искључиво на претњу да ће отетом лицу нанети тешку телесну повреду, без обзира што та претња није реализована, односно повреда није нанета, казна се не може ублажити. Међутим, ако услед отмице наступи смрт отетог лица, казна се учиниоцу може ублажити. Већи минимум запрећених казни за ст. 4. и 5. тиме губи на значају. Животно искуство и систем вредновања тежине кривичних дела не оправдавају решење законодавца.

Одредбом члана 57. став 2. искључено је ублажавање казне за кривична дела **силовања, обљубе са дететом и обљубе над немоћним лицем**, за све облике извршења ових кривичних дела. Опште примедбе на увођење института забране ублажавања казне важе и за ова кривична дела.

Међутим, чини се да је управо код ових кривичних дела значајно разликовање покушаја од свршеног кривичног дела, уз подсећање да се ради о тзв. двоактним кривичним делима. Тако ће се радње учиниоца покушаног кривичног дела силовања из ст. 2. чл. 178. КЗ свести на (неостварену) претњу учиниоца да ће за то или њему блиско лице открити нешто што би шкодило његовој части или угледу, па ће учинилац бити осуђен на казну затвора у трајању од најмање 2 године. Учинилац је само претио да ће открити нешто што би шкодило части или угледу жртве (као код кривичног дела изношења личних и породичних прилика из чл. 172. за које је, за свршено дело, предвиђена новчана казна) али овде у циљу остварења обљубе. На исту казну може бити осуђен и учинилац који је према жртви применио силу значајног интензитета, у дужем временском периоду, па потом кривично дело и довршио. Јасно је да постоји значајна разлика у количини криминалне делатности коју су учиниоци испољили, па се забрана ублажавања, са аспекта минималног могућег кажњавања, показује неоправданом.

Значајнија је чињеница да **ван забране ублажавања казне остаје кривично дело обљубе злоупотребом положаја** из чл. 181. КЗ. Разлика у кажњавању је повезана не са својствима жртве, ни са начином извршења дела, већ са својствима извршиоца и то, чини се, наопако.

Наиме, када школски друг, комшија, познаник, који је и млађе пунолетно лице, који нема било какве друштвене, моралне или законом утвр-

ђене обавезе према детету, који је у њу заљубљен, покуша да изврши обљубу над њом (чл. 180. КЗ), мора бити осуђен на казну затвора најмање 3 године. Животно: ученик четвртог разреда средње школе покуша а не изврши обљубу са ученицом осмог разреда основне школе.

Када обљубу изврши наставник, васпитач, старалац, усвојилац, родитељ, очух, маћеха, или друго лице злоупотребом свог положаја или овлашћења, може бити осуђен на казну затвора у трајању од 1 године и то за свршено дело. При томе учинилац може бити у зрелом животном добу а жртва стара, примерице, само 5, 6 или 7 година (чл. 181.. став 3). Разлика је још драстичнија ако је дело имало за последицу трудноћу јер ће се извршилац из чл. 180. КЗ осудити најмање 5 година а извршилац са посебним обавезама на казну затвора 5 пута мању, односно најмање 1 годину. Чини се да је наopakост законског решења очигледна.

Даље, уколико је жртва не дете већ малолетно лице па наставник, васпитач, старалац...остваре обљубу са тим малолетним лицем, минимална је казна затвора у трајању од 3 месеца а уколико извршилац без посебних својстава само покуша да оствари обљубу са малолетним лицем претњом да ће за то или њему блиско лице открити нешто што би шкодило његовој части или угледу, казниће се најмање казном затвора у трајању од 5 година, чак 20 пута већом казном.

Наравно да искључење, односно дозвољеност ублажавања казне са истим нелогичностима остају и за облике извршења кривичних дела из чланова 178. став 4, 179. став 3. и 180. став 3. КЗ, на једној страни, и члана 181. став 5. КЗ, на другој страни.

Забраном из члана 57. став 2. КЗ обухваћени су и ст. 2. и 3. кривичног дела **изнуде** из члана 214. КЗ. Забрана ублажавања не односи се на облике овог кривичног из става 1. као и из ст. 4. и 5. када су ови облици извршени у вези ст. 1. до 3.

Одредбе става 2. и 3. разликују се од основног облика из става 1. само прописаним цензусима и то за став 2. износа преко 450.000 динара а за став 3. износа преко 1.500.000 динара. Наравно да и облици кривичног дела из ставова 2. и 3. могу остати у покушају, тако да претходна излагања важе и за ово кривично дело.

Не може се рационално објаснити зашто ће учинилац кривичног дела изнуде који је оштећеном само претио тражећи износ незнатно преко 450.000 динара, али дело није довршио нити новац добио, бити осуђен најмање 2 године затвора а учинилац који је применом силе (не претње) довршио кривично дело и себи прибавио износ незнатно испод 450.000 динара, који по правилу оштећеном никада неће бити враћен, осуђен на казну затвора осам пута мању, од најмање 3 месеца.

Као и код кривичног дела отмице и код овог кривичног дела забрањено је ублажавање за облике кривичних дела из ставова 2. и 3. а дозвољено за квалификоване облике из ставова 4. и 5. што, уз претходно изложену принципијелну примедбу, доводи до парадоксалних ситуација. Извршилац кривичног дела у покушају из става 3. ове одредбе, мора бити осуђен на казну затвора у трајању од најмање 3 године а истом казном могу бити кажњени учиниоци тог дела извршеног у саставу групе или организоване криминалне групе или учинилац који се бави (у виду заната) вршењем овог кривичног дела. Уз све ово, темељни принцип разликовања кривичних дела из става 2. и става 3, цензус или висина имовинске користи, губи се код квалификованих облика из ставова 4. и 5.

Супротно од претходних кривичних дела, код кривичног дела недозвољеног преласка државне границе и кријумчарења људи из члана 350. забрањено је ублажавање казне, не за основне, већ за квалификоване облике кривичног дела из ставова 3. и 4. ове одредбе.

Законодавац је искључио ублажавање казне за кривично дело **неовлашћене производње и стављања у промет опојних дрога** из члана 246. КЗ и то за ставове 1. и 3. овог кривичног дела. Истовремено су измењене одредбе чланова 246, 246а и 247 ст. 3. и 4. КЗ. Измене су таквог значаја да изазивају бројне дилеме и захтевају посебну пажњу и превазилазе тему овог реферата. Међутим, остајући на терену примене члана 57. ст. 2. КЗ уочавамо да је искључено ублажавање казне када је кривично дело извршила група (најмање 5 година) а да је дозвољено ако га је извршила организована криминална група (запрећена је казна затвора од 10 година али се може ублажити до 7 година). Остаје принципијелна примедба решењу да се забрани ублажавање казне када су извршиоци група а дозволи када су извршиоци организована криминална група.

Законодавац то „пегла“ разликом у висини запрећених казни. Тиме се враћамо на претходни део овог реферата, да се исти циљ могао постићи већим минимумом запрећених казни.

Надаље, не може се поуздано утврдити критеријум законодавца приликом одређивања кривичних дела за која је одредбом члана 57. став 2. КЗ забранио ублажавање казне. У претходном делу реферата је указано на нелогичности до којих доводи чињеница да кривично дело обљубе злоупотребом поверења из члана 181. КЗ није обухваћена забраном а кривична дела из чланова 178, 179. и 180. КЗ јесу. Затим, забрањено је ублажавање казне за кривично дело трговине људима из члана 388. КЗ док су ван забране остала кривична дела трговине малолетним лицима ради усвојења (члан 389) и кривично дело заснивања ропског односа и превоз лица у ропском односу или забрањено је ублажавање казне за кривично дело отмице из члана 134. став 2. и 3. КЗ а није за кривично дело угрожавања лица под међународном заштитом из члана 392. КЗ (измена "Сл. гласник РС", бр. 121/2012) иако ово кривично дело у свом опису садржи отмицу.

Одредба садржана у ставу 3. члана 57. забрањује ублажавање казне учиниоцу који је раније осуђиван за истоврсно кривично дело (до измена објављених у "Сл. гласник РС", 121/2012 за исто кривично дело). Тиме се делимично дерогира одредба члана 55. КЗ да се та околност може а не мора ценити као отежавајућа околност. Даље, потпуно се искључује оцена протеча временског периода од раније извршеног кривичног дела па до актуелног. Оправдана је недоумица да ли осуђиваност за кривично дело ситне крађе треба да индукује забрану ублажавања казне извршиоцу кривичног дела тежје крађе у покушају а могли би се навести и други, слични, примери.

Допуњена је одредба садржана у ставу 8. чл. 57. КЗ. Ограничења садржана у овој одредби односе се на кривична дела за која је запрећена новчана казна са назначењем најмање мере. КЗ је садржао само 2 кривична дела и 3 њихова облика за која је прописана новчана казна са назначењем најмање мере: кривично дело клевете из чл. 171. (у међувремену брисано) и увреде из чл. 170. и то за ст. 1. и 2. Наравно да се тиме отвара дилема да ли је било нужно уводити посебну одредбу општег дела КЗ за новчане казне прописане за само два, сада једно, кривична дела или је у одредби тог кривичног дела ваљало одредити новчану казну у целини, а одредбу општег дела брисати. С обзиром да је на ову чињеницу већ указивано, то се доношењем ЗИД КЗ ова нелогичност могла отклонити.

Уместо тога, задржана је нелогичност у члану 57. став 1. тачка 8. да се новчана казна може ублажити до 10.000 динара. Значи не и испод овог износа, иако је одредбом чл. 50. ст. 2. КЗ већ прописано да новчана казна не може бити мања од 10.000 динара (општи минимум новчане казне). Дакле, посебно ограничење само је изједначено са општим минимумом. Судови нису ни овлашћени да учиниоца осуде на новчану казну испод 10.000 динара, јер би га осудили на казну која у Законику не постоји. Прописујући, на пример, казну затвора до 3 године законодавац нигде не наводи „од колико“, односно општи минимум, па доследно томе ни одредба члана 57. став 1. тачка 8. КЗ не треба да садржи општи минимум. Исто важи и за одређивање најмање новчане казне одређене у дневним износима.

Закључимо да је одредба члана 57. став 1. тачка 8. КЗ потпуно непотребна, јер прописује границе које су већ прописане као минималне у члану 49. став 2. и члану 50. став 2. КЗ, односно као општи минимум новчаних казни. Њеним брисањем овлашћења суда остала би иста.

Тешко је препознати чиме се законодавац руководио прописивањем члана 57. став 2. ЗИД КЗ. Оно што се не доводи у сумњу јесте да је и ова одредба у духу измена Законика као целине: поопштравања казнене политике. Међутим, уколико се и прихвати овај захтев као основан, иако повремено са призвоком популистичког, сигурно да се овом одредбом није допринело једноставности и чистоти законских решења на која се односи ова одредба. Ни правичности.

Однос према институтима ЗКП

Одредба чл. 57. ст. 2. КЗ дерогира примену одредбе члана 282б став 3. ЗКП, која предвиђа да се окривљени и јавни тужилац, закључујући **споразум о признању кривице**, под условима предвиђеним у овој одредби, могу сагласити да казна окривљеном буде ублажена. Већ у ставу 3. члана 282б одређено је да се јавни тужилац и окривљени могу сагласити да се окривљеном изрекне блажа казна али у границама прописаним у члану 57. КЗ, па самим тим и границама које одређује односно забрањује став 2. ове одредбе. Додатно ограничење за ублажавање казне по овом основу је и у одредби члана 282в став 9. којом је одређено да ће суд одбити споразум ако предложена казна не одговара тежини кривичног дела, што суд упућује опет на примену одредаба о висини казне, па тиме и одредбе члана 57. став 2. КЗ.

Дакле, ако се казна окривљеном, поновимо, супротно члану 282б став 3. ЗКП, не може ублажити, јер ту могућност искључује члан 57. став 2. КЗ, онда су његови мотиви да испуни услове предвиђене овом одредбом заиста минимални, готово искључени. Услови предвиђени овом одредбом су изузетно значајни:

- оцена да би доказивање кривичног дела без признања окривљеног било немогуће или знатно отежано;

- одлучни значај признања окривљеног за спречавање, откривање или доказивање других кривичних дела;

- постојање нарочито олакшавајућих околности из чл. 54. ст. 2. КЗ.

Тешко је наћи оправдање да одредба која одређује границе ублажавања казне, искључи примену овог института, посебно када се без признања оптуженог не може доказати извршење кривичног дела, јер на тај начин и окривљени и саизвршиоци, подстрекачи и помагачи остају ван домаћаја кривичног прогона. Да ли је у тој ситуацији претежнији интерес државе у инсистирању на забрани ублажавања казне или да допусти да окривљеном казна буде ублажена зато што ће кривично дело бити и откривено и доказано и тај окривљени, његови саизвршиоци, помагачи... осуђени?

Нема рационалног оправдања, нити оправдања са становишта криминалне политике државе, да се окривљени за кривично дело отмице из члана 134. став 2. или 3. КЗ уместо ублажене казне у трајању од 1 до 3 године мора осудити на казну затвора у трајању од најмање 3 године, ако би се његовим признањем спречило извршење те али и будуће, већ планиране, отмице. Примерице, окривљени може бити спреман да призна кривично дело, да призна где је оставио везаног отетог ... у замену за ублажену казну. Међутим, његова понуда не може бити прихваћена, јер му се казна не може ублажити. То важи и за остала кривична дела побројана у члану 57. став 2. КЗ.

Овакво решење законодавца је директно супротстављено одредби члана 4. став 2. КЗ односно: да је сврха изрицања кривичних санкција сузбијање кривичних дела, односно дела којима се повређују или угрожавају вредности заштићене кривичним законодавством, посебно када је признање окривљеног од одлучног значаја за спречавање или откривање других кривичних дела (повезано са чланом 282б ЗКП).

ЗКП је, очигледно, на истим разлозима на којима се темељи споразум о признању кривице, засновао институт **сведока сарадника**. Претпоставка стицања статуса сведока сарадника је да окривљени, припадник организоване криминалне групе, против кога се води кривични поступак за кривична дела из члана 504а став 3. овог законика, потпуно призна извршење кривичног дела и да је значај његовог признања за откривање, доказивање или спречавање других кривичних дела организоване криминалне групе претежнији од последица кривичног дела које је учинио (чл. 504о ЗКП).

Сведоку сараднику се утврђује минимална казна прописана КЗ за кривично дело које је учинио а затим се тако утврђена казна изриче умањена за половину, према члану 504т став 1. ЗКП (у Законику, непотребно, пише „једну“ половину, јер да су две то би значило ослобођење од казне а три и више половина казне не постоји, као и да казна затвора не може бити мања од 30 дана јер је то већ општи минимум ове казне). Дакле, суд сведоку сараднику казну не ублажава већ умањује за половину па нема колизије ове одредбе и одредбе члана 57. став 2. КЗ. Међутим у ставу 2. исте одредбе се наводи да када су испуњени услови предвиђени овим ставом суд сведоку сараднику казну може ублажити, што суд за дела побројана у члану 57. став 2. КЗ не би могао учинити због забране ублажавања у истој одредби, али то ипак може, јер је чланом 504т став 2. предвиђена и могућност ослобађања од казне а чланом 57. став 4. КЗ одређено је да се казна може ублажити мимо ограничења прописаних ставовима 1. до 3. ове одредбе ако је суд овлашћен да учиниоца кривичног дела ослободи од казне. Зато одредба члана 504т ЗКП бар није усклађена са чланом 57. КЗ.

Вероватно због претходно изложених нелогичности предложено је укидање спорног дела одредбе члана 57. КЗ у поступку доношења измена КЗ, потом објављених у "Сл. гласник РС", бр. 121/2012 али је, нажалост, предлог повучен у скупштинској процедури.

СУДСКА ПРАКСА

КРИВИЧНО ПРАВО

КРИВИЧНО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

УСЛОВНИ ОТПУСТ МАЛОЛЕТНИКА КОД ВАСПИТНЕ МЕРЕ УПУЋИВАЊЕ У ВАСПИТНО ПОПРАВНИ ДОМ

(Чл. 22. и 119. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела
и кривично правној заштити малолетних лица)

Приликом одлучивања о молби за условно отпуштање малолетника са извршења васпитне мере, првостепени суд ће ценити кумулативно испуњење законских услова који се тичу времена које је малолетник провео у васпитној установи, његово понашање и успех постигнут у васпитању након чега ће моћи да правилно утврди да ли се малолетник тако поправио да се на основу успеха постигнутог у васпитању може основано очекивати да он неће убудуће вршити кривична дела и да ће се у средини у којој буде живео добро владати, а нарочито да неће вршити кривична дела.

Из образложења:

Решењем Вишег суда у Прокупљу Куо. км. бр. 1/13 од 21.03.2013. године, одбијена је као неоснована молба малолетног сада пунолетног Р.М., из Прокупља за пуштање на условни отпуст из Васпитно поправног дома у Крушевцу, коме је решењем Вишег суда у Прокупљу Км. бр. 43/11 од 27.12.2011. године изречена васпитна мера упућивање у Васпитно поправни дом у трајању од најмање 6 месеци, а највише 4 године.

По налажењу Апелационог суда правилност утврђеног чињеничног стања произилази из правилне оцене извештаја Васпитно поправног дома у Крушевцу број 230-9/76 од 28.02.2013. године из кога је правилно утврђено да је понашање и владање малолетника у почетку било непримерено, због чега је дисциплински кажњаван, али да се од октобра 2012. године реализација васпитне мере креће узлазном путањом, да је праг толеранције на фрустрацију на просечном нивоу, да није у довољној мери самокритичан у односу на извршена кривична дела, те да, иако је све планиране испите положио са dobrим резултатима, мотивисан да заврши средњу

школу у оквиру Дома и да има подршку породице, сврха изрицања васпитне мере упућивања у Васпитно поправни дом још увек није остварена, јер малолетник није реализовао третман предвиђен од стране стручног тима Пријемног одељења.

Овај суд налази да је правилно првостепени суд оценио да у конкретном случају нису кумулативно испуњени законски услови за пуштање на условни отпуст малолетног сада пунолетног Р.М., јер из поменутог извештаја произилази да се програм поступања остварује успешно, али да још увек није постигнута сврха изрицања васпитне мере, па имајући у виду ову чињеницу, затим природу и тежину извршених кривичних дела, као и сврху кажњавања у смислу одредбе чл. 22. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица и чл. 42. Кривичног законика, овај суд налази да напред изнете чињенице које се тичу владања малолетног сада пунолетног Р.М. за време трајање мере ипак не указују да се малолетник тако поправио да се на основу успеха постигнутог у васпитању може основано очекивати да он неће убудуће вршити кривична дела и да ће се у средини у којој буде живео добро владати, а нарочито да неће вршити кривична дела.

(Решење Вишег суда у Прокупљу Куо. км. бр. 1/13 од 21.03.2013. године, решења Апелационог суда у Нишу 5Кжм. 2. бр. 5/13 од 11.04.2013. године)

Приредила: Милица Алексић,
судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу

**МУНИЦИЈА НАМЕЊЕНА
ЗА ИЗАЗИВАЊЕ АКУСТИЧНОГ ДЕЈСТВА
(Чл. 348. КЗ)**

Муниција намењена за изазивање акустичног дејства није предмет извршења кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл. 348. Кривичног законика.

Из образложења:

„Побијаном пресудом оптужени је оглашен кривим, због кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл. 348. ст. 3. у вези ст. 1. и 2. Кривичног законика, да је неовлашћено држао 38 комада муниције са зеленим врхом калибра. 22 long, пуњених ненадражујућим гасом.

Из налаза вештака произилази да наведена муниција спада у гасне меткове, тзв. „праскавце“, односно „плашљивце“, који служе само за изазивање звучног ефекта – праска и да исти нису пуњени никаквим иритантима.

Стога, имајући у виду да се ради о небојевој муницији намењеној за изазивање акустичног дејства, односно пуцња и да се њоме не може остварити никакво дејство на циљу, то иста не може бити предмет извршења кривичног дела из чл. 348. Кривичног законика“.

(Пресуда Општинског суда у Нишу К. бр. 2676/2009 од 07.12.2009. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж. 1. бр. 2208/10 од 17.01.2012. године)

Приредио: Зоран Ђурђевић, судијски сарадник

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ

(Члан 194. ст. 1. КЗ)

Кривично дело насиље у породици из чл. 194. ст. 1. Кривичног законика се према истом оштећеном не може извршити у продуженом трајању.

Из образложења:

„Првостепени суд је погрешно применио кривични закон на штету окривљеног када је његове радње правно квалификовао као два продужена кривична дела насиље у породици из чл. 194. ст. 1. у вези чл. 61. Кривичног законика, због чега је Апелациони суд у погледу правне квалификације кривичног дела, по службеној дужности у смислу чл. 391. ЗКП преиначио пресуду, налазећи да се у радњама окривљеног стичу обележја два

кривична дела насиље у породици из чл. 194. ст. 1. Кривичног законика, а не ова два кривична дела у продуженом трајању.

Ово стога што је кривично дело насиље у породици трајно кривично дело, чија је последица угрожавање спокојства, телесног интегритета или душевног стања члана своје породице, тако да се ово дело у свом основном облику може извршити са једном или више радњи, чија последица траје краће или дуже време, а имајући у виду природу дела, да се ради о једном континуираном стању у коме се налази један члан породице, услед радњи које предузима други члан породице према њему. Стога предузимање више радњи у једном дужем временском периоду не представља кривично дело у продуженом трајању, већ једно кривично дело, те се ради о трајном кривичном делу, које се може извршити са више радњи и чија последица може трајати и дуже време.

Апелациони суд је по службеној дужности побијану пресуду преиначио у погледу правне квалификације радњи извршења кривичног дела и окривљеног осудио за два кривична дела насиље у породици из чл. 194. ст. 1. КЗ, а не за два продужена кривична дела насиље у породици из чл. 194. ст. 1. у вези чл. 61. Кривичног законика“.

(Пресуда Основног суда у Врању К. бр. 765/11 од 02.02.2012. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 6Кж. 1. бр. 1934/12 од 23.04.2013. године)

Приредила: Драгана Живадиновић, судија

ЗАСТАРЕЛОСТ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА И МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ

Кад се има у виду да је окривљени извршио више противправних дела која су по закону одређена као кривична дела и да је за нека наступила застарелост кривичног гоњења та околност је без значаја на правилност и законитост одлуке о изреченој мери безбедности обавезног психијатријског лечења на слободи и на дужину њеног трајања.

Из образложења:

Решењем Основног суда у Нишу 1К. бр. 4501/10 од 25.10.2012. г., према окривљеном М.М. изречена је мера безбедности обавезно психија-

тријско лечење на слободи, које ће трајати док постоје потребе за лечењем али не дуже од три године, а ако се окривљени не подвргне лечењу на слободи или самостално напусти лечење или поред лечења наступи опасност да поново учини противправно дело предвиђено у закону као кривично дело тако да је потребно његово лечење и чување у одговарајућој здравственој установи изрећи ће се мера безбедности обавезно психијатријско лечење и чување у таквој установи.

Стоје наводи браниоца да је за радњу кривичног дела насиље у породици из чл. 194. ст. 1. КЗ за коју се окривљени терети извршена дана 25.03.2008. г. у односу на оштећеног Н.Н. застарело кривично гоњење на дан 25.03.2012. г. то јест пре доношења побијаног решења, кад се има у виду да је за исто прописана новчана казна или затвор до једне године, а сходно чл. 103. тач. 7. КЗ за исто се кривично гоњење не може предузети кад протекне две године од извршења дела а чл. 104. тач. 6. КЗ да застарелост кривичног гоњења настаје у сваком случају кад протекне двоструко време које по закону тражи за застарелост кривичног гоњења, како је то прописано кривичним закоником који је важио у означено време извршења ("Сл. гл. РС", бр. 107/2005).

Одредба чл. 82. КЗ прописује да ће суд учиниоцу који је у стању неурачунљивости учинио противправно дело које је по закону предвиђено као кривично дело, изрећи меру безбедности обавезно психијатријско лечење на слободи ако утврди да постоји озбиљна опасност да учинилац учини противправно дело које је у закону предвиђено као кривично дело и да је ради отклањања ове опасности довољно његово лечење на слободи.

Тумачењем наведене законске одредбе јасно произилази да је за изрицање наведене мере безбедности довољно да учинилац изврши само једно противправно дело као и да се изриче само једна мера безбедности, при чему на дужину трајања исте није од значаја да ли је лице према коме је изречена предузело једно или више противправних дела, већ потреба за његовим лечењем и успешност лечења у циљу отклањања опасности да учини противправно дело.

Кад се има у виду да је окривљени извршио више противправних дела која су по закону одређена као кривична дела и да је иста учинио и пре цитираног, то што је за исто наступила застарелост кривичног гоњења

у време доношења наведене одлуке је без значаја на правилност и законитост одлуке.

(Решење Основног суда у Нишу 1К. бр. 4501/10 од 25.10.2012. г и Апелационог суда у Нишу 2 Кжс. 1. бр. 601/13 од 07.03.2013. године)

Приредила: Љиљана Миљковић, судија

**РАДЊА ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА
СКИДАЊЕ И ПОВРЕДА СЛУЖБЕНОГ ПЕЧАТА И ЗНАКА
ИЗ ЧЛАНА 327. СТАВ 1. КЗ**

Радња извршења овог кривичног дела не може се одредити алтернативно, односно да је окривљени сам или преко трећег лица скинуо дистрибутивну пломбу са бројила.

Из образложења:

Првостепени суд је окривљеног огласио кривим за кривично дело које му се ставља на терет, односно да је критичном приликом сам или преко трећег лица скинуо службени печат, тако што је скинуо дистрибутивну пломбу, коју је на електрично бројило ставио овлашћено лице оштећеног предузећа. Оваква изрека је неразумљива, јер се радња извршења овог кривичног дела не може одредити алтернативно, већ је неопходно поуздано утврдити да ли је окривљени сам предузео наведену радњу или је то учинио преко трећег лица, што у конкретном случају није учињено. На ову повреду се указује жалбом окривљеног, и то наводима да није доказано да је он то учинио и на који начин.

Такође су нејасни разлози првостепеног суда у односу на утврђивање умишљаја код окривљеног, јер се у образложењу пресуде наводи да је окривљени као корисник електричног бројила имао интерес да на наведени начин скине службени печат, како би свом локалу обезбедио електричну енергију, која је претходно искључена због дуга. Међутим, то што је окривљени из наведених разлога имао мотив да предузме ове радње, није довољно да би се закључило да је управо он скинуо дистрибутивну плом-

бу, како му се ставља на терет оптужним предлогом, већ је потребно да се ова одлучна чињеница несумњиво утврди.

(Пресуда Основног суда у Нишу 2К. бр. 3178/11 од 30.01.2012. године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж. 1. бр. 1356/12 од 08.02.2013. године)

Приредила: Горана Митић, судија

КРИВИЧНО ДЕЛО НЕОВЛАШЋЕНО НОШЕЊЕ ОРУЖЈА ИЗ ЧЛАНА 348. КЗ

Неовлашћено ношење оружја подразумева одређено временско ношење оружја од стране лица које нема овлашћење за ношење оружја.

Из образложења:

Основано се жалбом првостепена пресуда побија у односу на оптуженог А. С. који је оглашен кривим за кривично дело из чл. 348. ст. 1. КЗ, јер првостепени суд није прихватио правну квалификацију из оптужнице, којом му се ставља на терет извршење кривичног дела из чл. 348. ст. 4. у вези ст. 1. КЗ.

По налажењу Апелационог суда, разлози првостепеног суда за измену правне квалификације су нејасни и противречни и за сада се не могу прихватити. Ово из разлога што првостепени суд закључује да изведеним доказима није потврђено да је он критичном приликом носио наведено оружје, већ да га је само држао код себе, при чему прихвата одбрану другог оптуженог, који је изјавио да је критичном приликом овај пиштољ предао оптуженом А. С. зато што је био пијан, а оптужени А. С. је у својој одбрани то потврдио, наводећи да му је овај оптужени предао пиштољ да га не би изгубио или направио неко дело, те да је он прихватио да пиштољ буде код њега док не пођу кући.

Међутим, с обзиром на изведене доказе, као и одбране оптужених, не може се закључити да оптужени А. С. критичном приликом није носио овај пиштољ, имајући у виду да је исти био код њега у периоду од када му је други оптужени исти предао, па све док није наишла полиција, када је код њега исти пронађен и одузет. Стога се не могу прихватити разлози пр-

востепеног суда да на овај начин оптужени А. С. није овај пиштољ носио у овом периоду, те да је исти само држао код себе. Ово из разлога што неовлашћено ношење оружја, према одредбама Кривичног законика, подразумева одређено временско ношење оружја од стране лица које нема овлашћење за ношење оружја, па је било потребно поуздано утврдити временски период од када је оптужени А. С. овај пиштољ примио од другог оптуженог, где је све боравио у том периоду, па до када је исти био код њега, те да ли је код оптуженог постојала свест и воља да манифестује власт над оружјем, односно да исто држи као своје или бар чува као туђе.

(Пресуда Вишег суда у Лесковцу К. бр. 4/11 од 10.02.2012. године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж. 1. бр. 1828/12 од 05.03.2013. године)

Приредила: Горана Митић, судија

КРИВИЧНО ДЕЛО СПРЕЧАВАЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА У ВРШЕЊУ СЛУЖБЕНЕ РАДЊЕ ИЗ ЧЛАНА 322. СТАВ 1. КЗ

Када окривљени спречава извршног радника суда у обављању службене радње, односно спровођењу привремене мере, треба утврдити садржину привремене мере у парничном предмету.

Из образложења:

Основано се жалбом браниоца окривљеног првостепена пресуда побија због битне повреде одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП, јер је првостепена пресуда донета уз наведену битну повреду, зато што су разлози о одлучним чињеницама, који се односе на постојање кривичног дела и кривицу окривљеног, нејасни и противречни.

Наиме, првостепени суд је окривљеног огласио кривим да је критичном приликом спречио овлашћено службено лице, односно извршног радника Основног суда у Врању, у обављању службене радње, тако што му је најпре упутио речи увреде и претње, ближе наведене у изреци пресуде, а када је извршни радник уклонио дрвену препреку, легао је испод камиона, због чега је оштећени одустао од предузимања даљих службених радњи.

Основано се жалбом браниоца окривљеног побија првостепена пресуда, због битне повреде одредаба кривичног поступка, наводима који се односе на спровођење привремене мере, односно да је иста у целости извршена, с обзиром да је извршни радник требало да уклони препреке на путу, а да није имао налог да спроводи камион преко парцеле окривљеног.

По налажењу Апелационог суда, првостепени суд није утврдио одлучне чињенице, које су од утицаја у овом поступку, односно није на поуздан начин утврдио садржину привремене мере у парничном предмету П. бр. 7000-94/10, односно да ли оштећени као извршни радник требало да само уклони дрвену препреку или је требало и да омогући пролаз камиона. Ово се не може утврдити из списка предмета, с обзиром да нису здружени списи парничног предмета у коме је донета ова привремена мера. Из исказа окривљеног, оштећеног, као и сведока, произилази да је оштећени извршио уклањање дрвене препреке, па је било неопходно поуздано утврдити да ли је на овај начин обавио службену радњу.

(Пресуда Основног суда у Врању К. бр. 184/11 од 05.07.2011. године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж. 1. бр. 630/12 од 11.12.2012. године)

Приредила: Горана Митић, судија

КРИВИЧНО ДЕЛО НЕДОЗВОЉЕНА ТРГОВИНА ИЗ ЧЛАНА 243. СТАВ 1. КЗ

Кривично дело недозвољене трговине из чл. 243. ст. 1. КЗ врши се и посредовањем у трговини.

Из образложења:

Првостепени суд је окривљеног ослободио од оптужбе, сматрајући да није доказано да је извршио кривично дело које му се ставља на терет. При томе, у образложењу пресуде првостепени суд је цитирао исказе сведока, па је исте прихватио, налазећи да су истинити и уверљиви. Међутим, из списка предмета произилази да су сведоци у истражном поступку сведочили да су продавали дрва окривљеном 2008. године и да им је он плаћао, док су на главном претресу тврдили да је окривљени био посред-

ник и да је доводио купце који су им плаћали. Стога је нејасно које исказе наведених сведока је суд прихватио, с обзиром да су исти давали различите исказе током поступка.

Такође, првостепени суд утврђује да је окривљени проналазио купце и био посредник приликом продаје дрва, али закључује да није био умешан у недозвољену трговину. Овакви разлози првостепеног суда су нејасни и противречни и за сада се не могу прихватити. Ово због тога што кривично дело недозвољена трговина из чл. 243. ст. 1. КЗ, које се окривљеном ставља на терет, врши лице које, немајући овлашћење за трговину, набави робу или друге предмете у већој вредности у сврху продаје или ко се неовлашћено и у већем обиму бави трговином или посредовањем у трговини или се бави заступањем организација у унутрашњем или спољнотрговинском промету робе и услуга. Дакле, као једна од радњи извршења овог кривичног дела наводи се и посредовање у трговини. Стога се основано жалбом Основног јавног тужиоца у Врању првостепена пресуда побија наводима да је окривљени, према исказима сведока, посредовао у трговини, те да је погрешан закључак првостепеног суда да нема доказа да је извршио кривично дело које му се ставља на терет.

(Пресуда Основног суда у Врању К. бр. 1172/10 од 09.06.2011. године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж. 1. бр. 429/12 од 27.11.2012. године)

Приредила: Горана Митић, судија

КРИВИЧНО ДЕЛО ТЕШКА КРАЂА ИЗ ЧЛАНА 204. СТАВ 1. ТАЧКА 1. КЗ У ПОКУШАЈУ

Када је окривљени затечен у продавници, на којој је разбио стакло на улазним вратима, неопходно је поуздано утврдити шта је том приликом намеравао да одузме.

Из образложења:

Првостепени суд је оптуженог ослободио од оптужбе применом чл. 355. тач. 2. ЗКП, због кривичног дела тешка крађа из чл. 204. ст. 1. тач. 1. у вези чл. 30. Кривичног законика, налазећи да није доказано да је извр-

шио ово кривично дело. При томе, првостепени суд налази да је неспорно да је оптужени разбио стакло на улазним вратима продавнице и ушао у намери да узме алкохолно пиће, али да нема доказа да је имао намеру да изврши тешку крађу, већ да се ради о ситној крађи, а да се оштећени није придружио кривичном гоњењу, нити истакао имовинскоправни захтев, па је суд прихватио одбрану оптуженог и ослободио га од оптужбе.

Међутим, из исказа сведока полицајаца не може се утврдити шта су конкретно затекли у овој продавници, с обзиром да су изјавили само то да су оптуженог затекли у извршењу кривичног дела, при чему је оптужени потврдио да је узео лименку са пивом, а првостепени суд и поред тога што утврђује да се ради о ситној крађи, ослобађа га од оптужбе. Стога се овакви разлози за сада не могу прихватити, с обзиром да чињенично стање није потпуно и правилно утврђено, на шта се указује жалбом Основног јавног тужиоца у Врању, јер изведени докази нису правилно цењени, па је требало поуздано утврдити одлучне чињенице, које се односе на понашање оптуженог критичном приликом и постојање његове намере приликом уласка у ову продавницу.

(Пресуда Основног суда у Врању К. бр. 3703/10 од 13.09.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж. 1. бр. 1596/12 од 19.02.2013. године)

Приредила: Горана Митић, судија

КРИВИЧНО ДЕЛО НЕДОЗВОЉЕН ПРОМЕТ АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА ИЗ ЧЛАНА 176. СТАВ 1. ЗППА

Ово кривично дело се врши стављањем у промет, односно продајом производа који нису посебно обележени прописаним контролним акцизним маркицама у складу са законом, при чему својство извршиоца није објективни услов инкриминације.

Из образложења:

Првостепени суд је окривљеног ослободио од оптужбе применом чл. 355. тач. 2. ЗКП, прихватајући одбрану окривљеног и налазећи да нема доказа да се у његовим радњама стичу елементи бића кривичног дела које му се ставља на терет, јер нема доказа да је он произвођач или увозник

акцизних производа, нити има доказа да је исте стављао у промет. При томе се позива на одредбе Закона о акцизама, које се односе на дефиницију произвођача акцизних производа, увозника истих, као и обвезника акциза, дајући своје тумачење шта се сматра стављањем у промет акцизних производа, из кога произилази закључак првостепеног суда да окривљени није био обвезник акцизе, ни као произвођач ни као увозник акцизних производа, нити је стављао исте у промет.

Међутим, првостепени суд није извршио правилну оцену наведених писаних доказа, у смислу одредбе чл. 352. ст. 2. ЗКП, које је само цитирао, након чега је закључио да није доказано да је окривљени извршио ово кривично дело. Стога су нејасни разлози првостепеног суда, јер се за сада не може прихватити закључак да окривљени није стављао у промет акцизне производе, како му се ставља на терет оптужним предлогом. Наиме, кривично дело недозвољен промет акцизних производа из чл. 176. ст. 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији чини онај ко ставља у промет, односно продаје производе који нису посебно обележени прописаним контролним акцизним маркицама у складу са законом. Дакле, радња извршења је стављање у промет или продаја, а ради се о трговини – куповини, продаји или замени производа домаћег или иностраног порекла, који подлежу плаћању акциза, а ови производи у моменту пуштања у промет нису обележени на законом прописани начин контролним акцизним маркицама, што значи да се радња извршења предузима на противзаконит начин, кршењем прописа о акцизама. Иначе, извршилац овог кривичног дела може бити свако лице, а у погледу виности потребан је умишљај.

(Пресуда Основног суда у Врању К. бр. 2879/10 од 08.02.2011. године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж. 1. бр. 4342/11 од 02.11.2012. године)

Приредила: Горана Митић, судија

УГРОЖАВАЊЕ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА ЧЛАН 289. СТАВ 3. У ВЕЗИ СТАВА 1. КЗ

Допринос учесника у саобраћају за настану саобраћајну незгоду није законски основ за његову кривичну одговорност.

Из образложења:

Из побијане пресуде произилази да је првостепени суд прихватио налазе и мишљења вештака саобраћајне струке Драгутина Илића и вештака машинске струке, Драгана Марковића, налазећи да су исти сагласни у техничком делу, а да се разликују у датом мишљењу, при чему се у пресуди наводи мишљење обојице вештака о томе да је конкретну саобраћајну незгоду узроковао оштећени који је управљајући возилом марке „Мазда“, вршећи небезбедно претицање трактора, када за то нису постојали безбедни услови због наиласка возила „Мерцедес“ из супротног смера, за окривљеног створио изненадну ситуацију, те да су се вештаци различито изјаснили само у погледу степена доприноса окривљеног за настанак саобраћајну незгоду, јер вештак Драгутин Илић сматра да је допринос окривљеног значајан, чак можда једнак пропусту оштећеног, а вештак Драган Марковић да је допринос окривљеног незнатан.

Осуђујућа пресуда за кривично дело које је окривљеном стављено на терет неизоставно би морала бити заснована на утврђењу које се тиче повреде неке од одредаба Закона о безбедности саобраћаја, што је у конкретном случају поступање супротно одредби чл. 35. ст. 1. тач. 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, која одредба се односи на обавезу да се возило држи на десној страни коловоза и што ближе десној ивици коловоза, али морала би бити заснована и на утврђењу да постоји узрочно последична веза између тог пропуста и настале саобраћајне незгоде, која у конкретном случају није утврђена јер из налаза вештака на којима суд заснива побијану пресуду произилази само допринос окривљеног за настанак саобраћајне незгоде.

Из првостепене пресуде се не може утврдити на који начин је и из којих доказа суд утврдио да је окривљени својим понашањем узроковао саобраћајну незгоду и лако телесно повређивање оштећеног, нити којим разлозима се је руководио приликом чињенично правних закључивања, па је пресуда захваћена битном повредом одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП јер не садржи јасне, одређене и на закону засноване разлоге о одлучним чињеницама и укинута је уважавањем жалбе браниоца који на наведену битну повреду основано указује.

(Решење Апелационог суда у Нишу 5Кж. 1. бр. 3808/12 од 14.05.2013. године, пресуда Основног суда у Нишу 10К. бр. 2528/11 од 17.08.2012. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

ТЕШКА КРАЂА - ЧЛАН 204. КЗ

Околност да је учинилац противправно одузету ствар продао отпаду по знатно нижој цени од њене реалне вредности, сама по себи, није довољна за закључивање да је његов умишљај био усмерен на прибављање мале имовинске користи и да у његовим радњама недостаје битан елемент кривичног дела тешка крађа из чл. 204. КЗ.

Из образложења:

Жалбом се наводи да је погрешно утврђено да је окривљени прибавио имовинску корист у износу од 117.965,00 динара јер је мењач, који је предмет извршења кривичног дела, отпаду продао за 8.000,00 динара, те се по ставу жалбе ради о кривичном делу ситне крађе из чл. 210. КЗ.

Без обзира по којој цени је окривљени предметни мењач продао, умишљај учиниоца да одузимањем туђих покретних ствари прибави себи противправну имовинску корист утврђује се према вредности ствари која је противправно одузета. Окривљени је одузимајући предметни мењач прибавио противправну имовинску корист у износу вредности истог и његова вредност је поуздано утврђена налазом вештака економске и машинске струке, па је без утицаја на другачије одлучивање по којој цени је окривљени одузету ствар даље продао и да ли ју је уопште продао, јер је окривљени продајући мењач отпаду по веома ниској цени свакако знао да се не ради о реалној вредности одузете ствари.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 5Кж. 1. бр. 3783/12 од 14.05.2013. године, пресуда Основног суда у Прокупљу 1К. бр. 931/11 од 13.07.2012. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

ТЕШКА КРАЂА - ЧЛАН 204. КЗ

Кривично дело крађа из чл. 203. КЗ, а самим тим и кривично дело тешка крађа из чл. 204. КЗ постоји и када учинилац одузима другом туђу покретну ствар са намером да за другог прибави противправну имовинску корист.

Из образложења:

Према правилном утврђењу првостепеног суда, у радњи извршења кривичног дела учествовали су заједно обојица оптужених и малолетни П.Д., па се истицањем да суд не цени да је корист од извршења дела имао само малолетник не доводи у питање ни правилност примене закона.

Ово стога што кривично дело тешка крађа из чл. 204. КЗ врши учинилац крађе уз околности које представљају квалификаторни елемент овог кривичног дела, а у смислу чл. 203. КЗ крађу чини онај ко туђу ствар одузме другом у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист, а у конкретном случају оптужени су је прибавили за малолетног П.Д.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 5Кж. 1. бр. 2206/12 од 16.05.2013. године, пресуда Основног суда у Врању К. бр. 614/10 од 21.02.2012. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

ЗАКОН О АМНЕСТИЈИ**ЧЛАН 1. СТАВ 1.**

Изречена новчана казна, која је на основу чл. 51. ст. 2. Кривичног законика замењена казном затвора, не подлеже амнестији у смислу чл. 1. ст. 1. Закона о амнестији.

Из образложења:

Основано се жалбом јавног тужиоца побија правилност првостепеног решења, јер је исто донето уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. Законика о кривичном поступку, имајући у виду да је изрека решења неразумљива и противречна датим разлозима.

Наиме, одредбом чл. 1. ст. 1. Закона о амнестији („Службени гласник Републике Србије“, број 107/2012) прописано је да се од извршења ослобађају лица која су правноснажно осуђена на казне затвора за кривична дела која су прописана законима Републике Србије или су била прописана законима који су престали да важе, а која се на дан ступања на снагу овог закона

налазе на издржавању казне затвора у Републици Србији или још нису ступила на издржавање казне затвора или чији премештај је ради издржавања те казне извршен у иностранство, што значи да се од извршења казне затвора ослобађају лица којима је изречена казна затвора, што овде није случај, јер осуђеном И.М. наведеном пресудом није изречена казна затвора већ му је изречена новчана казна која је замењена казном затвора обзиром да исту није платио у одређеном року, па је првостепени суд погрешно утврдио да наведена осуда подлеже амнестији и за такву одлуку дао нејасне и неприхватљиве разлоге, чиме је учино наведену битну повреду, на коју се жалбом основано указује, због чега је првостепено решење морало бити укинато.

У поновном поступку одлучивања, првостепени суд ће отклонити наведени недостатак на који је указано овим решењем, тако што ће након поновне оцене свих релевантних околности, правилном применом чл. 1. ст. 1. Закона о амнестији утврдити да ли су испуњени законски услови за примену амнестије према осуђеном И.М., при чему ће ценити и да ли осуђени има још неку правноснажну осуду која се може амнестирати, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку, за коју ће дати јасне и непротивуречне разлоге.

Казне затвора, по пресуди Основног суда у Прокупљу Кв. бр. 157/11 од 07.03.2012. године, осуђени се може ослободити у смислу чл. 51. ст. 3 Кривичног закона плаћањем новчане казне на коју је осуђен.

(Решење Апелационог суда у Нишу 5Кж. 2. бр. 1588/12 од 13.12.2012. године, решења Основног суда у Прокупљу Кв. бр. 534/12 од 28.11.2012. године)

Приредила Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

ЗАКОН О АМНЕСТИЈИ - ЧЛАН 4.

Околност да је за окривљеним до ступања на снагу закона о амнестији наређењно издавање потренице због нејављања на издржавање казне, искључује могућност амнестирања казне на коју је учинилац осуђен.

Из образложења:

Правилно је првостепени суд у побијаном решењу утврдио де се у конкретној кривично правној ствари нису стекли сви законски услови за примену амнестије према осуђеном, о чему су дати јасни и довољни разлози које у свему прихвата и овај суд.

Из побијаног решења произилази да је првостепени суд ценио околности да је осуђени С. Ђ. из Лесковца правноснажном пресудом Основног суда у Лесковцу 2К. бр. 93/11 од 23.01.2012. године оглашен кривим због два кривична дела недавање издржавања из чл. 195. ст. 1. КЗ и осуђен на јединствену казну затвора у трајању од три месеца, а такође правилно утврдио на основу извештаја Основног суда у Прокупљу Ик. бр. 123/12 од 17.01.2013. године да је за окривљеним С. Ђ. до дана ступања на снагу Закона о амнестији наређено издавање потернице због нејављања на издржавање казне и да је иста стављена ван снаге датумом јављања, као и да је започео са издржавањем казне 17.12.2012. године у Окружном затвору у Прокупљу.

(Решење Апелационог суда у Нишу 5Кж. 2. бр. 149/13 од 31.01.2013. године, решење Основног суда у Лесковцу Кв. бр. 11/13 од 18.01.2013. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА ИЗ ЧЛАНА 368. СТАВ 2. ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ У ВЕЗИ ЧЛАНА 23. ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА

О захтеву јавног тужиоца за привремено одузимање имовине проистекле из кривичног дела, првостепени суд одлучује након одржаног рочишта.

Из образложења:

Првостепеним решењем усвојен је захтев Вишег јавног тужиоца у Прокупљу ОИК бр. 1/11 од 06.04.2012. године за привремено одузимање имовине од окривљеног Д.М. и трећег лица Б.С., па је од окривљеног Д.М. Са личним подацима као у изреци побијаног решења привремено одузета покретна ствар-путничко моторно возило марке „BMW 524 TDE 34” регистарске ознаке РК 011 LI, сиве метализиране боје Д5, са бројем шасије WBANA51060BA54886 и бројем мотора 246TB26076851075, произведено 1990. године.

Чланом 23. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела одређено је да ће суд пре доношења одлуке о захтеву за привремено одузимање имовине заказати рочиште на које ће позвати власника, његовог браниоца, односно пуномоћника ако га има и јавног тужиоца. Имајући у виду да првостепени суд није одржао рочиште, ускратио је право странкама, па и браниоцу да се изјасне о чињеницама и доказима важним за овакву одлуку, на који начин им је ускраћена могућност да се изјасне о предлогу јавног тужиоца и пружи доказе о томе како је окривљени Д.М. стекао имовину чије се привремено одузимање тражи. Такође, из првостепеног решења се не може утврдити да ли окривљени поседује имовину и које је вредности, те да ли је постоји основана сумња да је имовина ближе

наведене у изреци побијаног решења у очигледној несразмери са законитим приходима окривљеног, а што је услов за усвајање захтева јавног тужиоца за привремено одузимање имовине, из ког разлога се доводи у питање правилност закључивања првостепеног суда да од окривљеног Д.М. треба привремено одузети имовину.

(Решење Вишег суда у Прокупљу ПОИ 6/12 од 24.12.2012. године, решење Апелационог суда у Нишу 5Кж2. ПОИ бр. 55/13 од 26.02.2013. године)

Приредила: Милица Алексић,
судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу

**БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
ИЗ ЧЛАНА 368. СТАВ 1. ТАЧКА 11. ЗАКОНИКА
О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ У ВЕЗИ ЧЛАНА 34. СТАВА 2.
ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ
ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА**

Изрека решења о трајном одузимању имовине мора да садржи опис и законски назив кривичног дела и број пресуде са датумом правноснажности којом је за то дело окривљени оглашен кривим и осуђен.

Из образложења:

„Побијано решење садржи битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368. став 1. тачка 11. Законика о кривичном поступку, на коју је основано истиче у жалбама, јер је изрека решења неразумљива, а решење нема разлога о одлучним чињеницама. Наиме, чланом 34. ст. 2. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела одређено је да решење о трајном одузимању имовине садржи податке о власнику, опис и законски назив кривичног дела, податке о имовини која се одузима, односно вредност која се одузима од власника ако је располагао имовином проистеклом из кривичног дела у циљу осујећења њеног одузимања и одлуку о трошковима управљања привремено одузетом имовином.

Дакле, у изреци решења о трајном одузимању имовине мора да стоји опис и законски назив кривичног дела и број пресуде са датумом прав-

носнажности којом је за то дело окривљени оглашен кривим и осуђен, те како иста не садржи опис кривичног дела, већ само да је због продуженог кривичног дела проневера из чл. 364. ст. 3. у вези ст. 1. КЗ окривљени осуђен правноснажном пресудом Окружног суда у Приштини, која је преиначена пресудом Врховног суда Србије, то је по налажењу Апелационог суда изрека побијаног решења неразумљива“.

(Решење Вишег суда у Косовској Митровици Тош. бр. 1/10 од 30.06.2011. године и решење Апелационог суда у Нишу 6Кж. 2. тош. бр. 1089/11 од 21.11.2012. године).

Приредила: Драгана Живадиновић, судија

СВЕДОЧЕЊЕ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОПЕРАТИВНО ПОСТУПАЛИ У ОДНОСУ НА ОПТУЖЕНОГ

Уколико полицијски службеници на главном претресу сведоче о својим непосредним опажањима у вези са извршењем кривичног дела, то околност да су поднели кривичну пријаву против оптуженог, не доводи у сумњу њихову непристрасност као сведока.

Из образложења:

„По налажењу Апелационог суда, чињеница да су сведоци Д.Д. и З.Н. у својству службених лица оперативно поступали у односу на оптуженог П.П., као и да је Д.Д. подносилац кривичне пријаве против оптуженог не доводи у сумњу њихову непристрасност и објективност, обзиром да су сведочили о својим непосредним опажањима, те како су искази ових сведока јасни, убедљиви и међусобно сагласни, жалбени наводи да је реч о лицима заинтересованим за исход поступка и да су њихови искази нелогични због чега их није требало прихватити, оцењени су као неосновани“.

(Пресуда Вишег суда у Нишу 1К. бр. 77/10 од 02.12.2010. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 2Кж. 1. бр. 341/11 од 29.11.2012. године).

Приредио: Зоран Ђурђевић, судијски сарадник

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

(Члан 368. став 1. тачка 11. Законика о кривичном поступку)

Код оцене да ли ће се осуђени условно отпустити са издржавања казне затвора, не води се рачуна о општој сврси кажњавања, већ се цени дали је у односу на осуђеног постигнута сврха кажњавања.

Из образложења:

Наиме, из списка предмета произилази, да је решењем Вишег суда у Прокупљу Куо. бр. 5/13 од 07. фебруара 2013 године, одбијена као неоснована молба осуђеног В.Б. за условно отпуштање са издржавања казне затвора изречене правноснажном пресудом Окружног суда у Прокупљу К. бр. 57/05 од 10. маја 2006. године.

Основано се жалбом осуђеног В.Б. указује, да је побијано решење захваћено битним повредама одредаба кривичног поступка, јер је по налажењу Апелационог суда учињена битна повреда из члана 368. став 1. тачка 11. Законика о кривичном поступку, из разлога што су дати разлози о чињеницама битним за постизање циљева како опште тако и посебне превенције, нејасни.

По налажењу Апелационог суда у Нишу, овакав закључак првостепеног суда се не може прихватити, имајући у виду, да је одредбом чл. 4. Закона о изменама и допунама Кривичног законика ("Службени гласник РС", бр. 121 од 24. децембра 2012 године), члан 46. став 1. Кривичног законика измењен и у другој реченици се каже: "При оцени да ли ће се осуђени условно отпустити узеоће се у обзир његово владање за време издржавања казне, извршење радних обавеза, с обзиром на његову радну способност, као и друге околности које показују да је у односу на њега постигнута сврха кажњавања". То значи да се код оцене да ли ће се осуђени условно отпустити са издржавања казне затвора, не води се рачуна о општој сврси кажњавања, већ се цени да ли је у односу на осуђеног постигнута сврха кажњавања, те нема места оцени да ли је условно отпуштање осуђеног у складу са циљевима опште превенције.

(Решење Вишег суда у Прокупљу Куо. бр. 5/13 од 07.02.2013. године и Решење Апелационог суда у Нишу 14Кж2 бр. 263/12 од 22.02.2013. године)

Приредио: Горан Димитријевић,
виши судијски сарадник

**БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
ИЗ ЧЛАНА 368. СТАВ 1. ТАЧКА 10. ЗКП**

Записник о реконструкцији који је сачињен од стране председника већа без присуства записничара на реконструкцији у присуству стручних лица и вештака на лицу места који су сачињавали белешке а у циљу обављања предметне радње је доказ на коме се може засновати судска одлука и није доказ који је прибављен супротно одредби чл. 174. ст. 1. и 2. ЗКП.

Из образложења:

Пресудом Вишег суда у Нишу 2К. бр. 465/10 од 26.12.2011. г., оптужени П.И. из Г.Л., оглашен је кривим за кривично дело тешко убиство из чл. 114. ст. 1. тач. 5. КЗ у стицају са кривичним делом убиство из чл. 113. КЗ у покушају у вези чл. 30. КЗ у стицају са кривичним делом неовлашћено држање оружја и експлозивних материја из чл. 348. ст. 2. у вези ст. 1. КЗ, и осуђен на јединствену казну затвора у трајању од тридесет година.

Указујући на повреду одредбе из чл. 368. ст. 1. тач. 10. ЗКП бранилац оптуженог тврди да је пресуда заснована на доказу на коме се не може заснивати јер је исти прибављен супротно одредбама ЗКП. Објашњава да је у питању записник о реконструкцији 2К. бр. 465/10 од 31.03.2011. године, који није сачињен у складу са одредбама чл. 174. ст. 1. и ст. 2. ЗКП, јер су током предузимање радње реконструкције сачињаване белешке од стране криминалистичког техничара и вештака балистичара да из записника произилази да је сачињен од стране председника већа. Даље наводи, да је у конкретном случају могао бити обезбеђен записничар, што није учињено, а да закон прописује као изузетак да записник може бити сачињен од стране другог лица.

Одредба чл. 112. ст. 1. ЗКП прописује да орган који обавља увиђај или реконструкцију може затражити помоћ стручног лица криминалистичко – техничке, саобраћајне или друге струке, које ће по потреби, предузети и проналажење, обезбеђивање или описивање трагова, извршити потребна мерења, снимања, сачинити скице или прикупити друге податке, а ст. 2. да се на увиђај или реконструкцију може позвати вештак ако би његово присуство било од користи за давање налаза и мишљења. Тумачењем наведене законске одредбе произилази да иста овлашћује да орган који предузима наведене радње увиђај или реконструкцију може да затражи помоћ од стручног лица, вештака, те и да та лица сачињавају белешке у том циљу.

Како бранилац не спори присуство криминалистичких техничара и вештака и да су они том приликом сачињавали белешке, код чињенице да се ради о хитном поступку, јер се оптужени налази у притвору који му је одређен на основу одлуке првостепеног суда, при чињеници да се радња предузимала ван службених просторија првостепеног суда, то што записник није сачинио записничар и што су присутна лица стручна лица и вештаци на лицу места сачињавали белешке а у циљу обављања предметне радње, а записник је сачињен од стране председника већа, не чини предметни записник мањкавим, то јест да је исти сачињен супротно одредбама чл. 174. ст. 1. и 2. ЗКП. Из изнетих разлога Апелациони суд налази да предметни записник није недопуштен доказ, односно доказ на којем се не може заснивати пресуда, па се првостепена пресуда неосновано побија због битне повреде одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 10. ЗКП.

(Пресуда Вишег суда у Нишу 2К. бр. 465/10 од 26.12.2011. године и Пресуда Апелационог суда у Нишу 2Кж. 1. бр. 1731/12 од 03.07.2012. године)

Приредила: Љиљана Миљковић, судија

ПРЕСУЂЕНА СТВАР

Да би се радило о пресуђеној ствари, неопходно је да у решењу Прекршајног суда буду наведене радње окривљеног, које одговарају радњама које представљају обележје кривичног дела.

Из образложења:

Дати разлози првостепеног суда су нејасни и противречни и за сада се не могу прихватити. Ово због тога што из наведеног решења Општинског органа за прекршаје у Нишу произилази да је С.Р. оглашен одговорним да је дана 02.08.2009. године, у Нишкој Бањи, нарушавао јавни ред и мир заједно са осталим наведеним лицима, на тај начин што је дошао испред куће породице Д. и позивао М.Д. на тучу, због нерашчишћених односа, а када су из куће изашли Д., М. и С., дошло је до међусобне расправе и обостраног вређања, а даље се наводи да је тада Д.Д. узео металну шипку и њоме ударио С.Р. у пределу левог ребра, те да је С.Р. почео да

бежи низ улицу, када су га сустигли Д., М. и С. и задали више удараца по глави и телу. У кривичном поступку, окривљеном С.Р. ставља се на терет да је критичном приликом позвао оштећене С, М, Н. и Д.Д. да изађу у двориште, те да је онда ударио најпре оштећену Н. у пределу главе, затим дрвеном бејзбол палицом ударио С.Д. у пределу главе, онда Д.Д. такође палицом у пределу леве руке, као и М.Д. истом палицом у пределу зглоба леве руке и на овај начин им нанео лаке телесне повреде, описане у изреци пресуде.

Дакле, из наведеног произилази да у решењу Општинског органа за прекршаје нису описане радње окривљеног С.Р., које чине обележје кривичног дела које му се ставља на терет у кривичном поступку. Ово из разлога што је он оглашен одговорним због нарушавања јавног реда и мира, као и угрожавања мира и спокојства оштећених, при чему није описана конкретна радња којом је он повредио оштећене, већ из овог решења произилази да су оштећени повредили њега. Стога су нејасни разлози првостепеност суда да се ради о истом чињеничном стању у вези истог догађаја. Такође је нејасан закључак којим првостепени суд на основу тога што је против окривљеног обустављен прекршајни поступак да је критичном приликом код себе имао дрвену бејзбол палицу, те на основу исказа оштећених у прекршајном поступку, када су изјавили да је окривљени повредио све оштећене, утврђује да су на тај начин разматране све околности идентичне оптужби у овом кривичном поступку.

Да би се радило о пресуђеној ствари, неопходно је да у решењу Органа за прекршаје, односно Прекршајног суда буду наведене радње окривљеног, које су идентичне радњама које представљају обележје кривичног дела, без обзира на исход прекршајног поступка. У конкретном случају тога нема, с обзиром да у решењу Органа за прекршаје нису описане оне радње окривљеног, које би одговарале радњама, које му се стављају на терет у кривичном поступку.

(Пресуда Основног суда у Нишу 6К. бр. 5871/10 од 16.05.2012. године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кжс. 1. бр. 3093/12 од 12.04.2013. године)

Приредила: Горана Митић, судија

БИТНА ПОВРЕДА ИЗ ЧЛАНА 368. СТАВ 1. ТАЧКА 10. ЗКП

Полицијски службеник не може бити саслушан у својству сведока на околности сачињавања службене белешке у фази прикупљања обавештења.

Из образложења:

Првостепени суд је учинио битну повреду из чл. 368. ст. 1. тач. 10. ЗКП, јер је пресуду засновао на доказу на коме се иста не може заснивати. Ово из разлога што је сведок Н.Ф., који је полицијски службеник, саслушан у својству сведока пред судом на околности разговора са сведоком Р. В. у фази прикупљања обавештења, о чему је сачинио белешке, које су издвојене из списка предмета на основу решења првостепеног суда са главног претреса, одржаног дана 15.09.2011. године, а које су физички издвојене тек у жалбеном поступку.

Дакле, из наведеног произилази да је сведок Н.Ф. сведочио само на околности разговора са сведоком Р.В., а не о ономе што је лично запазио, због чега се на његовом исказу пресуда не може заснивати, па се стога основано изјављеним жалбама указује на учињену битну повреду, због чега се за сада не могу прихватити дати разлози првостепеног суда, који се односе на утврђено чињенично стање.

(Пресуда Вишег суда у Прокупљу К. бр. 33/11 од 15.09.2011. године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж. 1. бр. 3329/11 од 26.09.2012. године)

Приредила: Горана Митић, судија

**БИТНА ПОВРЕДА ИЗ ЧЛАНА 368. СТАВ 1. ТАЧКА 11. ЗКП
У ВЕЗИ ЧЛАНА 67. СТАВ 1. КЗ**

У поступку опозива условне осуде, треба најпре утврдити почетак и истек времена проверавања по претходној пресуди, да би се могло закључити да ли је окривљени извршио ново кривично дело у време проверавања.

Из образложења:

Првостепени суд је приликом изрицања условне осуде окривљеном применио одредбу чл. 67. ст. 1. КЗ, која се односи на опозивање условне осуде због новог кривичног дела. При томе утврђује да је претходном пресудом окривљеном изречена условна осуда са утврђеном казном затвора у трајању од два месеца и роком провере од једне године, налазећи да рок провере траје до 25.05.2008. године, с обзиром да је пресуда донета дана 25.05.2007. године.

Међутим, оваква изрека је неразумљива, с обзиром да се из списка предмета не може утврдити када је пресуда Општинског суда у Прокупљу од 25.05.2007. године постала правноснажна, јер рок провере почиње од дана правноснажности пресуде, а не од дана доношења исте, па се из истог разлога не може утврдити ни када је истекло време провере по претходној пресуди. Одредбом чл. 67. ст. 1. КЗ прописано је да ће суд опозвати условну осуду, ако осуђени у време проверавања учини једно или више кривичних дела, за која је изречена казна затвора од две године или у дужем трајању.

Из наведеног произилази да је ради примене наведене законске одредбе неопходно најпре утврдити почетак и истек времена проверавања по претходној пресуди, да би се могло закључити да ли је окривљени извршио ново кривично дело у време проверавања. Првостепени суд то није учинио, јер није здружио списе предмета како би утврдио ове одлучне чињенице, већ је само на основу датума доношења претходне пресуде закључио да рок провере траје до 25.05.2008. године.

(Пресуда Основног суда у Прокупљу 4К. бр. 746/10 од 04.08.2011. године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж. 1. бр. 3613/11 од 02.10.2012. године)

Приредила: Горана Митић, судија

НЕДОЗВОЉЕН ДОКАЗ

(Члан 368. став 1. тачка 10. ЗКП)

Одлука суда се може заснивати на исказу саизвршиоца, испитаног у својству сведока, према коме је поступак правноснажно окончан у одвојеном кривичном поступку.

Из образложења:

Жалбама одбране се истиче да је одлука суда заснована на исказу сведока малолетног П.Д. а да се, по ставу жалбе, исказ саучесника у извршењу кривичног дела не може користити као доказ у поступку. Иако се жалбама наводи да се овим наводима побија правилност утврђеног чињеничног стања, истима се суштински неосновано указује на битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 10. ЗКП изношењем сопственог става о томе да се одлука суда заснива на доказу на коме се не може заснивати.

Супротно изнетом, по налажењу овог суда, тиме што је одлуку засновао на исказу малолетног П.Д., саизвршиоца, према коме је поступак вођен раздвојено од поступка против оптужених и правноснажно окончан према одредбама Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица, првостепени суд није учинио наведену битну повреду јер саизвршилац према коме је поступак раздвојен не спада у круг лица из чл. 97. ЗКП које се не може испитати као сведок, већ напротив, исти може бити саслушан у својству сведока и његов исказ није доказ на коме се одлука суда не може заснивати.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 5Кж. 1. бр. 2206/12 од 16.05.2013. године, пресуда Основног суда Врању К. бр. 614/10 од 21.02.2012. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

**ПОВРЕДА ЗАКОНА У КОРИСТ ОКРИВЉЕНОГ – ПРИМЕНА
ЗАКОНА И ОБАВЕЗНО ИЗРИЦАЊЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ**

Када је суд пропустио да уз условну осуду окривљеном изрекне и новчану казну, чије је изрицање по закону обавезно, повредио је закон у корист окривљеног.

Из образложења:

Жалбом јавног тужиоца првостепена пресуда се побија због повреде кривичног закона истицањем да је првостепени суд прекорачио овлашћења која има по закону тиме што окривљеног, уз изречену условну осуду,

није осудио и на новчану казну, имајући у виду да је окривљени предметни револвер држао до 04.10.2010. године, те да је првостепени суд морао да примени Кривични законик објављен у "Службеном гласнику РС" бр. 72 од 03.09.2009. године.

По налажењу Апелационог суда, основано се жалбом јавног тужиоца указује на повреду кривичног закона, која повреда се огледа у прекорачењу овлашћења које суд има по закону, у конкретном случају, у корист окривљеног. Ово из разлога што из правилно утврђеног чињеничног стања произилази да је окривљени радње извршења кривичног дела неовлашћена производња и држање оружја и експлозивних материја из чл. 348. ст. 1. КЗ предузео закључно са 04.10.2010. године, у време када је на снази био Кривични законик Републике Србије („Службени гласник РС" бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 11/09), са последњом изменом објављеном у "Службеном гласнику РС", бр. 72 од 03.09.2009. године, који за наведено кривично дело прописује казну затвора у трајању од три месеца до три године и новчану казну, па је стога уз изречену условну осуду суд био у обавези да окривљеног осуди и на новчану казну, као споредну казну, која је законом прописана као обавезна.

Тиме што је окривљеном за извршено кривично дело изрекао условну осуду и то казну затвора у трајању од 5 месеци која се неће извршити уколико окривљени у року од две године по правноснажности пресуде не изврши ново кривично дело, без да му изрекне и новчану казну у одговарајућем износу, као споредну казну, која споредна казна је законом који је важио у време извршења кривичног дела била прописана као обавезна, првостепени суд је прекорачио овлашћење које има по закону и повредио кривични закон у корист окривљеног.

Поступајући на наведени начин првостепени суд је учинио повреду кривичног закона из чл. 369. ст. 1. тач. 4. ЗКП, погрешно налазећи да у конкретном случају има места примени блажег закона јер време извршења кривичног дела обухвата и период после наведене измене закона, односно после 11.09.2009. године.

Отклањајући наведени недостатак, Апелациони суд је преиначио побитану пресуду у делу одлуке о кривичној санкцији применом чл. 391. ЗКП којим је прописано да ће другостепени суд уважавајући жалбу или по службеној дужности пресудом преиначити првостепену пресуду ако утврди да су

одлучне чињенице у првостепеној пресуди правилно утврђене и да се, с обзиром на утврђено чињенично стање, по правилној примени закона има донети друкчија пресуда, тако што је окривљеног Г.С. за кривично дело неовлашћена производња и држање оружја и експлозивних материја из чл. 348. ст. 1. Кривичног законика, за које је наведеном пресудом оглашен кривим, уз условну осуду, осудио и на новчану казну у износу од 100.000,00 динара, коју је дужан да плати у року од три месеца, а уколико окривљени не плати новчану казну у одређеном року, суд ће исту заменити казном затвора тако што ће се за сваких започетих хиљаду динара новчане казне одредити један дан казне затвора, јер је изрицање споредне казне за наведено кривично дело у време извршења кривичног дела било прописано као обавезно, док је у непрекинутом делу иста пресуда остала неизмењена.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 5Кжс. 1. бр. 207/12 од 04.09.2012. године, пресуда Основног суда у Лесковцу 5К. бр. 1584/11 од 21.11.2011. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

ТРОШКОВИ ПОСТУПКА

(Члан 79. ст. 1. и 2. ЗМ)

Трошкови кривичног поступка спроведени у поступку према малолетнику падају на терет буџетских средстава иако је исти постао пунолетан.

Из образложења:

Жалбом се истиче да је у време доношења побијаног решења Т.К. био пунолетан и да би требало да сноси како трошкове лечења, за лекарско уверење, лекарске прегледе и лекове, путне трошкове, тако и накнаду за физички бол малолетне оштећене, њен претрпљени страх и душевни бол због наружености, те је жалбени предлог да се исти обавезе на такво плаћање.

Одредбом чл. 79. ст. 1. ЗМ прописано је да суд може малолетника обавезати на плаћање трошкова кривичног поступка и на испуњење имовинско правног захтева само ако је малолетнику изрекао казну, а ако је према истом изречена васпитна мера или поступак обустављен, трошкови

поступка падају на терет буџетских средстава а оштећени се ради остављавања имовинско правног захтева упућује на парнични поступак.

Из наведеног произилази да је првостепени суд правилно поступио када је побијаним решењем одлучио да у смислу наведене законске одредбе трошкови поступка падају на терет буџетских средстава и да се оштећени ради остваривања имовинско правног захтева упућују на парницу.

При испитивању изнетих жалбених навода овај суд је имао у виду и одредбу чл. 79. ст. 2. ЗМ којом је прописано да суд може одредити да малолетник плати трошкове поступка и испуни имовинско правни захтев и када према њему изрекне васпитну меру, односно када веће за малолетнике нађе да није целисходно изрећи малолетнику казну малолетничког затвора нити васпитну меру, али је услов за доношење овакве одлуке у смислу одредбе чл. 79. ст. 2. ЗМ да малолетник има приходе или имовину, која околност не произилази из личних података малолетног сада пунолетног Т. К. и стања доказа у списима предмета.

Жалбени навод да је Т. К. у време доношења побијаног решења био пунолетан те да се исти по том основу може обавезати на плаћање трошкова поступка и накнаду штете није од утицаја за другачије закључивање у овој кривично правној ствари имајући у виду да је према наводима предлога за изрицање кривичне санкције и утврђењу суда из побијаног решења наведена дела извршио као малолетник због чега је поступак према њему и спроведен према одредбама Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица.

(Решење Апелационог суда у Нишу 5Кжм. 1. бр. 49/12 од 13.09.2012. године, решење Вишег суда у Лесковцу Км. бр. 11/12 од 24.05.2012. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

НЕДОЗВОЉЕНА ЖАЛБА (Чл. 80. ЗМ и чл. 364. ЗКП)

Жалба законског заступника малолетног оштећеног изјављена због одлуке о кривичној санкцији није дозвољена.

Из образложења:

Решењем већа за малолетнике Вишег суда у Лесковцу Км. бр. 11/12 од 24.05.2012. године, према малолетном сада пунолетном Т. К. изречена је васпитна мера појачан надзор од стране органа старатељства у смислу чл. 11. ст. 1. тач. 2. и чл. 17. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица, која мера ће трајати најмање шест месеци а највише две године, о чему ће суд накнадно одлучити.

Истим решењем оштећени Н.И., С.М., Н.Р., оштећена малолетна Е.С., Д. и К.М., малолетни М.К., Н.Ж., М.Ђ. и С.Ђ., ради остваривања имовинско правног захтева упућени су на парнични поступак у смислу чл. 79. ст. 1. ЗМ, а истовремено је одлучено да трошкови поступка падају на терет буџетских средстава суда у износу од 8.003,00 динара, у смислу чл. 79. ст. 1. ЗМ.

Против овог решења жалбу је изјавила Е.С., законска заступница малолетне оштећене Е.С., без навођења законског основа побијања, а из садржине жалбе произилази да се истом побијају одлука о кривичној санкцији, имовинско правном захтеву и трошковима поступка, са предлогом да се решење преиначи и малолетном сада пунолетном Т.К. изрекне строжија кривична санкција, као и да се исти обавезе да оштећеној надокнади штету.

По налажењу овог суда, жалба законског заступника малолетне оштећене Е.С., у делу у којем се првостепено решење побија због одлуке о кривичној санкцији није дозвољена.

У смислу чл. 80. ЗМ, против решења веће за малолетнике, а сходно одредби чл. 364. Законика о кривичном поступку оштећени, па самим тим и његов законски заступник жалбу могу изјавити само због одлуке о трошковима кривичног поступка и имовинско правном захтеву, а истовремено оштећени није овлашћен да изјави жалбу и због одлуке о кривичној санкцији.

Стога, по овом законском основу изјављена жалба није дозвољена те је иста у смислу одредбе чл. 387. ЗКП одбачена као недозвољена.

(Решење Апелационог суда у Нишу 5Кжм. 1. бр. 49/12 од 13.09.2012. године, решење Вишег суда у Лесковцу Км. бр. 11/12 од 24.05.2012. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

ВРАЋАЊЕ ОПТУЖНИЦЕ ПО ПРИГОВОРУ

(Чл. 273, 274. и 275. ЗКП)

Недостатак изјашњења истражног судије да је истрага завршена оптужницу не чини неразумљивом и та околност није законски основ за њено одбацивање.

Из образложења:

Решењем Вишег суда у Пироту Кв. бр. 127/12 од 27.07.2012. године кривично веће одбацило је оптужницу Вишег суда у Пироту Кв. бр. 34/12 од 17.07.2012. године, као неуредну.

Против овог решења жалбу је изјавио Виши јавни тужилац у Пироту, због битне повреде одредаба кривичног поступка са предлогом да се решење укине и предмет врати првостепеном суду на поновни поступак.

Првостепено решење је захваћено битном повредом одредаба кривичног поступка, из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП, јер је изрека неразумљива и решење не садржи јасне разлоге о одлучним чињеницама, по ком основу се жалбом основано побија.

Наиме, из побијаног решења произилази да је Виши јавни тужилац у Пироту 17.07.2012. године подигао оптужницу против окривљеног Е.М. због кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл. 348. ст. 4. у вези ст. 2. и 1. Кривичног законика, да је бранилац окривљеног изјавио против исте приговор, те да је ванрасправно веће тог суда донело решење Кв. бр. 127/12 од 23.07.2012. године којим се тужилаштву враћа оптужница ради отклањања недостатака у самом поступку са образложењем да је потребно да тужилаштво затражи изјашњење од поступајућег истражног судије у предмету тог суда Ки. бр. 20/12 да ли исти, након приспећа вештачења вештака Мр. Сц. 3.С. сматра да је стање ствари у истрази довољно разјашњено, односно да ли је истрага завршена.

По налажењу овог суда изрека побијаног решења је неразумљива јер се из исте не може утврдити у чему се огледа неуредност предметне оптужнице.

Такође, првостепено решење је донето противно одредби чл. 171. ст. 2. ЗКП, на коју се суд позива јер се наведена законска одредба не одно-

си на одбачај поднесака упућених суду већ прописује да поднесци из става 1. истог члана морају бити разумљиви и садржати све што је потребно да би се по њима могло поступити, док је одбачај регулисан одредбом чл. 171. ст. 3. ЗКП који се пак може применити само када је реч о оптужници или оптужном предлогу оштећеног као тужиоца, како је то приписано у ставу 1. истог члана, али не и када се ради о оптужници јавног тужиоца у ком случају се примењују одредбе чл. 265. до чл. 282. ЗКП.

Жалбом Вишег јавног тужиоца основано се указује на незаконитост овог решења истицањем да је одредбама чл. 273, 274. и 275. Законика о кривичном поступку, којима је прописано поступање суда при одлучивању по приговору против оптужнице и које је суд био у обавези да примени, прописано овлашћење већа да врати оптужницу уколико уочи недостатке и погрешке да се недостаци отклоне или уколико сматра да је потребно боље разјашњење ствари, да се истрага допуни у смислу чл. 273. ст. 1. ЗКП, да се огласи ненадлежним уколико сматра да је надлежан други суд, у смислу чл. 273. ст. 2. ЗКП, да одлучи да нема места оптужби и да се поступак обуставља на основу чл. 274. ЗКП, или да оптужницу одбаци на основу чл. 274. ст. 2. ЗКП уколико постоје разлози предвиђени том одредбом, при чему је у смислу чл. 275. ст. 1. ЗКП веће овлашћено да оптужницу одбаци, али само из разлога наведених у тој одредби.

Имајући у виду наведено, Апелациони суд налази да у конкретном случају кривично веће није било овлашћено да одбаци оптужницу као неуредну, као и да се не ради о неуредном оптужном акту те да је Виши јавни тужилац био овлашћен да након увида у достављене списе предмета подигне оптужницу, тим пре што и из разлога побијаног решења произилази да је донето решење о спровођењу истраге и да су спроведене све истражне радње предложене од стране тужиоца.

(Решење Апелационог суда у Нишу 5Кж. 2. бр. 980/12 од 14. 08. 2012. године, решење Вишег суда у Пироту Кв. бр. 127/12 од 27. 07. 2012. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

СУДСКА ПРАКСА

ГРАЂАНСКО ПРАВО

ПРОЦЕСНО ПРАВО

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ

Уколико је спорни однос настао у вези са пословањем тужиоца који има статус правног лица и тужене као приватног предузетника која ради стицања добити обавља регистровану делатност, надлежан је привредни суд, а потраживање настало у правном односу између правног лица и власника радње застарева у општем застарном року од 10 година.

Из образложења:

У конкретном случају спорни однос је настао између тужиоца ЕД „Југоисток“ ДОО Ниш, Електродистрибуција Ниш и тужене као власнице кафе бара „ПП“, а због дуга на име утрошене електричне енергије.

По тужби предузећа као правног лица против туженог имаоца угоститељске радње за суђење је стварно надлежан привредни суд - суд друге врсте. Према одредбама чл. 25. ст. 1. тач. 1. Закона о уређењу судова, привредни судови су стварно надлежни да суде спорове између домаћих и страних привредних друштва, предузећа, задруга и предузетника и њихових асоцијација (привредни субјекти).

Како је у конкретном спорни однос настао у вези са пословањем тужиоца који има статус правног лица и тужене као приватног предузетника која ради стицања добити обавља регистровану делатност, то је према цитираној одредби Закона о уређењу судова за суђење у овој правној ствари надлежан привредни суд.

Радња нема страначку способност, јер нема својство правног лица, а страначку способност и право да буде странка у поступку има само власник радње као физичко лице. Надлежност основног, односно привредног суда одређује се управо према томе да ли је то лице (физичко лице) власник радње, када је надлежан привредни суд или је обично физичко лице, у ком случају је надлежан основни суд.

Према чл. 7. Закона о приватним предузетницима и чл. 85. Закона о привредним друштвима, физичко лице оснива радњу ради обављања делатности и стицања добити и за обавезе које проистичу у обављању делатности радње оснивач одговара целокупном својом имовином. Треба правити разлику између предузећа као правних лица која имају свој правни субјективитет одвојен од личности њихових власника, и предузетника који нема посебно организационо устројство и он је привредни субјекат који делује као појединац, те у конкретном случају није реч о међусобном потраживању правних лица. Потраживање настало у правном односу између правног лица и власника радње застарева у општем застарном року од 10 година.

Из тог разлога је неопходно поуздано утврдити да ли радња тужене још увек постоји или је евентуално одјављена и брисана из регистра. Уколико је тужена још увек власник радње за суђење је надлежан привредни суд, а уколико је радња одјављена, онда тужена нема својство власника радње, већ физичког лица, па је надлежан основни суд, а што ће првостепени суд имати у виду приликом поновног одлучивања у овој ствари.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу, 13 Гж.1066/12 од од 31.05.2012. године)

Приредили: Миодраг Марјановић, судија
и Јелена Увалин, судијски помоћник

ПАСИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ

Тужбом се може тражити утврђење права својине на стану као посебном делу зграде само према оним лицима - власницима станова, који то право тужиоцу као купцу стана оспоравају, односно према онима који га узнемиравају у коришћењу права својине, док би стамбена зграда била пасивно легитимисана само у спору који се односи на послове коришћења и одржавања, сходно одредби чл. 11. ст. 1. Закона о одржавању стамбених зграда.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању тужилац је са предузећем „Елмосдом“ из Јагодине дана 18.12.2008. године, закључио уговор о купопро-

даји непокретности оверен пред судом и то стана у Нишу у ул. Козарачкој у таванском делу стамбене зграде, површине 40 мкв. Тужени је у целости исплатио купопродајну цену продавцу и приликом покушаја да ступи у посед био је онемогућен од стране станара зграде и то В.К., председника скупштине станара и М. Д., који тужиоцу нису дали кључ од стана. Тужилац је поднеском од 24.05.2012. године, прецизирао тужбени захтев и као тужене поред стамбене зграде у Нишу у ул. Козарачкој, означио и В.К. и Д.М. На рочишту одржаном 19.07.2012. године, тужилац је прецизирајући тужбени захтев повукао тужбу у односу на тужене В.К. и Д.М.

Код овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је одбио тужбени захтев због недостатка пасивне легитимације на страни тужене стамбене зграде, налазећи да стамбена зграда у овој правној ствари није ни у каквом материјално правном односу са тужиоцем и да у материјално правном односу могу бити само власници станова уколико оспоравају тужачево право својине на предметном стану.

По оцени овог суда првостепени суд правилно закључује да не постоји пасивна легитимација тужене стамбене зграде у овој правној ствари, те је првостепена одлука којом је одбијен као неоснован тужбени захтев, правилна и на закону заснована.

Право својине на стану као посебном делу зграде тужбом се може тражити да се утврди само према оним лицима - власницима станова који то право тужиоцу као купцу стана оспоравају, односно према онима који га узнемиравају у коришћењу права својине. Према одредби чл. 11. ст. 1. Закона о одржавању стамбених зграда, стамбена зграда има својство правног лица у правним пословима које се односе на одржавање и коришћење стамбене зграде, па сходно томе стамбена зграда би била пасивно легитимисана само у спору који се односи на ове послове коришћења и одржавања. Како се у овој правној ствари ради о спору који се односи на утврђење права својине на стану у таванском делу зграде и предају државине тог стана, а не на његово коришћење, то је правилно првостепени суд закључио да стамбена зграда не може бити пасивно легитимисана јер није у материјално-правном односу са тужиоцем.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж.бр.35/13)

Приредили: Слађана Ђуричковић, судија
и Бети Лазаревић, судијски помоћник

СТРАНАЧКА СПОСОБНОСТ ОПШТИНСКИХ ОДБОРА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

Општински одбори политичких странака немају својство правног лица, па немају ни страначку способност.

Из образложења:

Према чл. 5. Закона о политичким странкама, политичка странка стиче статус правног лица даном уписа у Регистар политичких странака. Политичку странку заступа лице овлашћено за заступање политичке странке (заступник политичке странке), изабрано односно именовано на начин утврђен статутом. У Регистар се поред осталог уписује лично име заступника политичке странке. Организационе јединице по територијалном принципу немају статус правног лица. У конкретном случају, Општински одбор СПС и Општински одбор ДС немају својство правног лица, па немају ни страначку способност. Достављање писмена врши се достављањем правном лицу, а не организационој јединици која нема својство правног лица и није овлашћена за пријем писмена. Како су тужба и сви даљи поднесци и позиви, достављени Општинском одбору ДС, а не у седишту тужене Демократске странке као правном лицу, то је на наведени начин учињена апсолутна битна повреда чиме је пропуштањем уредне дожаве ускраћена могућност туженом да пред судом расправља.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу, 13 Гж.2534/12 од 06.12.2012. године)

Приредили: Миодраг Марјановић, судија
и Јелена Увалин, судијски помоћник

ТУЖБА ЗА УТВРЂЕЊЕ И ПРАВНИ ИНТЕРЕС ТУЖИОЦА

Тужилац има правни интерес за утврђење неког свог права ако је то право спорно. Постојање правног интереса је процесна претпоставка, чије постојање суд претходно цени према активностима у време подношења тужбе.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је са туженима 02.08.2005. године закључио уговор о заједничкој изградњи пословно-

стамбене зграде. Тим уговором, тужене су се између осталог, као титулари права коришћења на земљишту сагласиле да тужилац својим средствима на истом сагради пословно стамбену зграду, а да им он по изградњи преда у својину стамбене јединице које су ближе одређене у уговору. Уговорено је да ће уговорене стране, накнадно анексом уговора о заједничкој изградњи ближе одредити удео у наведеној непокретности свих уговараца, као етажних власника, на основу пројекта зграде. После изградње, тужилац је предао туженима стамбене јединице, али тужене нису са њим закључиле анекс уговора, па је тужилац поднео тужбу за утврђење својине 25.06.2009. године, након чега је решењем ДН 108/2010 од 25.02.2011. године и извршен земљишно књижни упис права својине.

На основу утврђеног чињеничног стања, нижестепени судови су одбацили тужбу, налазећи да је за подношење тужбе правни интерес тужиоца „у међувремену“ остварен правном заштитом у земљишнокњижном поступку односно укњижбом права својине на деловима непокретности, а на основу закљученог уговора о заједничкој изградњи.

Наиме, тужилац има правни интерес за утврђење неког свог права ако је то право спорно, у смислу члана 188. ЗПП. Постојање правног интереса је процесна препоставка, чије постојање суд претходно цени према околностима у време подношења тужбе. Пре подношења тужбе, тужене нису са тужиоцем закључиле анекс уговора, којим би се одредио удео странака на непокретности-деловима зграде (по закљученом уговору), па су самим тим оспориле право тужиоца, као етажног власника. Следствено изложеном, тужилац би имао правни интерес да у овом судском поступку захтева утврђење прав својине на делу непокретности.

Земљишнокњижни упис етажне својине, који је извршен после подношења тужбе у овом имовинскоправом спору, није од утицаја у оцени правног интереса, у смислу члана 188. ЗПП, па ће суд доношењем мериторне одлуке поступити по примедбама на које је указано овим решењем.

(Решење Апелационог суда у Нишу Г.ж. 1261/12 од 12.6.2012. године и Врховног касационог суда Рев. 70/2013 од 30.01.2013. године)

Аутор сенценце: Миомир Митровић, судија

ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ

ПРЕЛАЗ ОСИГУРАНИКОВИХ ПРАВА ПРЕМА ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ НА ОСИГУРАВАЧА (СУБРОГАЦИЈА)

(Члан 939. ЗОО)

Регрес исплаћеног износа накнаде штете може се тражити само према лицу које је одговорно за штету.

Из образложења:

Нису од утицаја жалбени наводи туженог И. да он није учествовао у вансудском поравнању које је закључено између тужиоца и оштећених, те не може прихватити било какво обавезивање од стране тужиоца за накнаду регреса исплаћеног оштећенима, ово због тога, јер је правилно првостепени суд у побијаној пресуди утврдио да је друготужени И. пресудом Окружног суда у Н. К. 103/04 од 11.11.2004. године оглашен кривим за кривично дело тешко дело против безбедности јавног саобраћаја, из чл. 201. ст. 2. у вези чл. 195. ст. 1. КЗ РС, које је извршио управљајући возилом марке „Застава 128“ рег бр. под дејством алкохола у крви од 1,08 до 1,13 промила, дана 30.12.2002. године, на тај начин што се кретао брзином 70 км/х, која је била недозвољена и неприлагођена густини саобраћаја, видљивости и особинама пута, када је налетео на сада пок Ј.М. као пешака, набацио на хаубу, након чега је оштећена пала, задобила тешке телесне повреде, од којих је преминула на путу до болнице. Покојна М. је била у браку са С. Ј. који је престао њеном смрћу, имала две кћери и то Н.К., а, Н. је у тренутку смрти мајке била малолетна. Вансудским поравнањем од 02.08.2007. године и 20.09.2007. године, тужилац је на име материјалне штете исплатио оштећенима, износе наведене у изреци побијане пресуде, а на име претрпљених душевних болова супруге, односно мајке и оштећеној И.Д. накнаду на име нематеријалне штете због душевних болова због губитка ћерке и материјалну штету набавке црнине.

У конкретном случају тужилац као осигуравајућа организација има право регреса према туженику-И. - возачу моторног возила, осигураног од одговорности према трећим лицима, који је штету проузроковао управља-

јући моторним возилом под дејством алкохола, јер је доказано да постоји узрочна веза између алкохолисаности, неприлагођене вожње условима пута и настанка штете, због чега је и тужени И. кривичном пресудом оглашен кривим за овај штетни догађај.

Осим тога тужени у жалби не оспорава висину штете која је исплаћена оштећенима, нити било којим доказима доводи у сумњу, да је иста неправилно утврђена.

Зато је правилно првостепени суд применио материјално право, одредбу чл. 939. ст. 1 ЗОО, којом је регулисан прелаз осигураникових права према одговорном лицу на осигуравача. Наиме, тужилац је са исплатом штете оштећенима, стекао право на регрес, даном када је извршио исплату, па има право и на законску затезну камату, а самим тим и на штету сходно чл 278. ЗОО.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу – 15Гж. бр. 1675/12 од 13.09.2012. године)

Приредила: Мирослава Миловановић, судија

ОБИМ НАКНАДЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ И ДОЦЊА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ЗА ШТЕТУ (Чл. 189. и 277. ст. 1. ЗОО)

Одговорно лице за насталу штету је дужно да успостави стање које би било да штета није настала. Кад успостављање ранијег стања није могуће, накнада материјалне штете се досуђује у новцу, а висина штете се одређује према ценама у време доношења судске одлуке и камата на износ материјалне штете досуђује, почев од дана доношења првостепене пресуде.

Из образложења:

Првостепени суд је правилном оценом изведених доказа у односу на наведене околности, укупне количине и врсте одузетих предмета поуздано утврдио, да је правноснажном пресудом Општинског суда у Врању К. 540/10, тужени осуђен за кривично дело тешке крађе у саизвршила-

штву, и у том поступку је утврђено, да су тужиоцима одузет златни накит, који је по броју и врсти тачно означен у изреци наведене кривичне пресуде. Исказима сведока је утврђено да су тужиоцима враћени предмети и то један женски прстен тежине 3,8 грама, један женски прстен израђен ручно са црвеним каменом тежине 5,7 грама, једна бурма која је покидана тежине 1,9 грама, а остали предмети који су покрадени, нису враћени. Вештачењем од стране вештака златара је утврђена вредност украдених предмета од злата и сребра који су предмет тужбеног захтева, а који нису враћени од стране туженог.

Ценећи овако утврђене чињенице, првостепени суд је правилном применом материјалног права, одредбе чл. 154. ЗОО обавезао туженог да тужиоцима накнади материјалну штету, насталу као последицу извршења кривичног дела.

Међутим, првостепени суд је погрешно применио материјално право, када је тужиоцима досудио камату, на износ накнаде материјалне штете од 500.435,00 динара, почев од 04.11.2010. године па до 21.11.2012. године, из следећих разлога:

Накнада материјалне штете се утврђује према одредбама чл. 185., 189. и 190. ЗОО. Значи, да у првом реду постоји обавеза лица одговорног за насталу штету да успостави стање које би било да штета није настала, према чл. 185. ст. 1. наведеног закона. Под условима из става 2., 3. и 4. исте законске одредбе накнада материјалне штете досуђује се у новцу и висина штете се одређује према ценама у време доношења судске одлуке, сходно чл. 189. ст. 2. ЗОО.

Тужиоци су у време закључења главне расправе, када је донета првостепена пресуда, остали при тужбеном захтеву, како у погледу висине штете, тако и у погледу камате.

Значи, у време закључења главне расправе у тренутку доношења првостепене пресуде, тужиоци су определили висину материјалне штете у износу који је првостепени суд досудио и без обзира на протек времена, дана вештачења 04.11.2010. год., и закључења главне расправе 22.11.2012 год. тужиоци нису захтевали да се утврди висина штете у време пресуђења.

Стога је у Апелациони суд преиначио првостепену пресуду у ставу 1. изреке, и одбио тужбени захтев за камату, почев од 04.11.2010. године

па до 21.11.2012. године, јер се висина материјалне штете утврђује у време доношења првостепене пресуде.

Пошто тужиоци имају право на законску затезну камату, почев од пресуђења 22.11.2012. године па до исплате, сходно чл. 277. ст. 1. ЗОО, у овом делу жалба тужиоца одбијена као неоснована и одлучено, као у изреци ове пресуде.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу – 15Гж.бр.328/13 од 14.03.2013. године)

Приредила: Мирослава Миловановић, судија

ОДНОС ПОВЕРИОЦА И ЈЕМЦА, СОЛИДАРНИ ДУЖНИЦИ (Члан 1004. ЗОО)

Солидарна обавеза не захтева да се у парници успостави јединствено супарничарство. Солидарни дужници образују процесну заједницу обичних супарничара и према чл. 1004. ст. 3. ЗОО није потребно да се истовремено од свих солидарних дужника захтева наплата спорног потраживања.

Из образложења:

Побијајући првостепену пресуду тужени у жалби истиче, да је обавезан на исплату износа од 1.275.052,21 динар, са каматом почев од 18.08.2009. године па до коначне исплате, по основу менице, које је издао, као средство обезбеђења потраживања, по основу уговора о издавању гаранције бр. 1082/04. Међутим, пресудом Основног суда у Нишу 9 П.1022/2012, обавезани су М.М. и М. М., из с. П. као хипотекарни дужници, да трпе намирење овог истог потраживања у износу од 4.106.059,21 динар, са законском каматом и то на износ од 1.275.052,21 динара са законском каматом, почев од 18.08.2009. године па до коначне исплате, као и на износ од 2.831.007,00 динара, са каматом почев од 19.07.2009. године па до исплате. Ради се о истом дугу, по истом уговору о издавању гаранције бр. 1082/04, па постоји идентитет тужбених захтева. Различитим пресудама по истом основу обавезују се солидарни дужници на исплату истог дуговања по различитим пресудама. Стога је првостепени суд по-

вредио законску одредбу чл. 1004. ст. 3. ЗОО којом је прописано да се наплата дуга од солидарних дужника може тражити или од једног, или од другог дужника, или пак од свих солидарних дужника али истовремено. Оваквим тужбеним захтевом се уноси правна несигурност, јер при оваквом стању ствари тужилац од сва три туженика може наплатити исто потраживање.

Изложени наводи жалбе по схватању Апелационог суда нису основани.

Предмет тужбеног захтева у овој ствари је дуг, на основу менице АА90338242, издате дана 17.08.2009. године, по којој је тужилац поверилац, а тужени солидарни дужник. Солидарна обавеза не захтева да се у парници успостави јединствено супарничарство. Солидарни дужници образују процесну заједницу обичних супарничара, а како они по чл. 1004. ст. 3. ЗОО., чине самосталне странке, према свим солидарним дужницима не мора се донети истовремена јединствена пресуда.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу – 15Гж.бр.316/13 од 14.03.2013. године)

Приредила: Мирослава Миловановић, судија

УГОВОРНА КАЗНА (Чл. 270. и 272. ЗОО)

Уговорна казна дели правну судбину главног уговора и може се уговорати само као санкција због неизвршења или неблаговременог извршења неновчане обавезе, а не и новчане обавезе.

Из образложења:

Према разлозима првостепене пресуде, тужила и тужени су закључили предуговор о купопродаји непокретности 18.02.2010. године овереним пред Основним судом у Нишу Ов. II 463/10, по коме су тужила у својству купца, а тужени у својству продавца постигли сагласност о купопродаји непокретности у стамбеном објекту у изградњи на кп. 7731 КО Ниш Пантелеј, површине 38,80 мкв, са подрумском просторијом, за купо-

продајну цену од 19.500,00 евра. У предуговору је наведено да продавци примају купопродајну цену на дан овере предуговора и предуговорач тужени М.С. се обавезао да у случају раскида предуговора, има обавезу враћања купопродајне цене. Рок за предају је одређен за 30.12.2011. године и након што се тужила обраћала туженима за продужење рока за предају кључева, предуговор није реализован. Приликом закључења наведеног предуговора, тужила је добила износ од 3.000 евра од туженог, с обзиром да је са њима раскинула уговор о купопродаји претходног стана, како би исти заменила за нови стан, чија је вредност процењена на 19.500 евра. За претходни стан тужена је исплатила туженима износ од 15.850 евра, исти јој није враћен, након што је пристала на замену првобитног стана, а није добила кључеве од новог стана, који је био уговорен предметним предуговором.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд закључује да су испуњени услови за раскид предуговора, због неизвршења обавезе и применом чл. 124. ЗОО, раскида предметни предуговор о купопродаји, ово и са разлога јер чињенице на којима тужила заснива свој тужбени захтев, друго тужени није оспорио поднеском, док је друготужена у односу на раскид предуговора због неизвршења, поднеском признала тужбени захтев и одлучује као у ст. 1. изреке.

Затим, тужбени захтев одређен на износ од 19.500 евра делимично усваја за износ од 15.850 евра, јер је тужила туженима предала стан за који је платила 15.850 евра, како би добила стан који вреди 19.500 евра, с тим што је приликом примопредаје од тужених добила износ од 3.000 евра.

На основу тога закључује да је тужила као уговорна страна испунила своју уговорну обавезу и да је на губитку за износ од 15.850 евра, који представља вредност стана, који је био предмет размене и за овај износ усваја тужбени захтев у ст., 2., изреке. Пошто, првотужени током расправе није оспорио чињеницу да је он дужан да врати повраћај примљеног износа како стоји у предуговору, тужбени захтев тужиоца за већи износ од 15.850 евра, а до износа од 19.500 евра, одбија као неоснован, применом чл. 210. ЗОО., и одлучује као у ст. 2. изреке.

Основано се у жалби тужиле истиче да је првостепени суд погрешно применио материјално право, када је за већи износ од досуђеног од

15.850 евра одбио тужбени захтев, из разлога што је неспорно утврђено да је купопродајна цена по предметном уговору за стан у износу од 19.500 евра. Када се од овог износа одбије износ од 3.000 евра, који је дат на име неиспуњења претходног уговора, остаје износ од 16.500 евра, који износ је тужени С.М., дужан да врати тужиљи.

Како је првостепени суд усвојио тужбени захтев тужиле за 15.850 евра, то произилази да је тужбени захтев тужиле основан још за 650 евра колико износи разлика између 16.500 евра и износа досуђеног од 15.850 евра. Зато је Апелациони суд у одбијајућем делу преиначио првостепену пресуду и тужилу досудио на име повраћаја дела купопродајне цене још 650 евра, са каматом по стопи Европске централне банке почев од 18.02.2010. године, па до исплате, све у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате.

Правилно је првостепени суд одбио тужбени захтев, на име повраћаја износа увећаног за 10 %, јер тужилца нема право на уговорну казну, у износу од 10% од уговорене цене, зато што је уговорна казна акцесорне природе и дели судбину главног уговора, који није закључен, а може се уговорати само као санкција због неизвршења, или неблаговременог извршења неновчане обавезе, а не и новчане обавезе, сходно чл. 270. ст. 3. и чл. 272. ст. 1. ЗОО.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу – 15Гж.бр.356/13 од 14.03.2013. године)

Приредила: Мирослава Миловановић, судија

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КРЕДИТА МЕНИЦОМ КАО ВЕРОДОСТОЈНОМ ИСПРАВОМ У ПОСТУПКУ ИЗВРШЕЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА

Првостепени суд је био дужан да пође од Закона о извршењу и обезбеђењу који у чл. 18. ст. 2. тач. 1. прописује да је веродостојна исправа меница и чек домаћег или страног лица, са протестом ако је то потребно за заснивање потраживања. Неопходност постојања протеста за заснивање потраживања цени се према одредбама Закона о меници.

Из образложења:

Према стању списка предмета дана 30.09.2008. године, закључен је уговор о кредиту за обртна средства и Анекс наведеног уговора између овде тужиоца, као банке и предузећа „Н.“ ДОО Ниш као корисника, а чији је законски заступник С.А., овде тужена, која је у уговору именована и као јемац платац. Из менице у списима предмета од 08.02.2010. године која гласи на износ од 715.099,55 динара, произлази да је у својству трасанта означена тужена С.А. Надаље, произлази да је тужилац дана 01.09.2009. године упутио обавештење фирми „Н.“ ДОО Ниш о раскиду наведеног уговора. Тужена је у току поступка истакла приговор недостатка пасивне легитимације, са разлога што потпис јемца не представља њен потпис, с тим што је она потписала уговор као законски заступник фирме Н. као и својеручно попунила бланко меницу. Из налаза и мишљења вештака графоскопске струке произлази да спорне потписе на уговору о кредиту за обртна средства и анексу наведеног уговора исписане испод речи „јемац платац“ није својм руком пописала тужена С.А.

Полазећи од наведених доказа првостепени суд налази да је тужбени захтев тужиље неоснован. Образлажући ову своју одлуку првостепени суд наводи да с обзиром на утврђење да на уговору о кредиту за обртна средства као и Анексу истог уговора потпис на месту јемца платца не представља својеручни потпис тужене, што значи да иста није изразила своју вољу да буде страна у облигационом односу у својству јемца платца, иста не може да буде обавезана да као јемац платац одговара солидарно са дужником.

Међутим, овакав закључак се за сада не може прихватити јер је првостепени суд пропустио да утврди све чињенице од којих зависи правилност одлуке те је побијана пресуда заснована на погрешној примени материјалног права.

Наиме, код неспорне чињенице да је тужена потписала бланко соло меницу, првостепени суд губи из вида да је у конкретном случају тужилац своје потраживање обезбедио и меницом, као инструментом обезбеђења плаћања кредита, поред уговора о јемству. Имајући у виду наведено првостепени суд је био дужан да пође од Закона о извршењу и обезбеђењу који у чл. 18. ст. 2. тач. 1. прописује да је веродостојна исправа меница и чек домаћег или страног лица, са протестом ако је то потребно за заснивање потраживања. Неопходност постојања протеста за заснивање потраживања цени се према одредбама Закона о меници. Чланом 27. ст. 1. Закона о

меници прописано је да се акцептом трасат (лице које је у меници означено као онај који треба да плати меничну суму, а које је ту обавезу признало сходно чл. 24. истог закона), обавезује да меницу плати по доспелости. Ставом два истог члана прописано је да ако меница не буде плаћена њен имаалац има на основу ње право на непосредну тужбу против акцептанта (трасанта), за све што се може захтевати према чл. 47. и 48. Закона о меници. У конкретном случају, а према стању у списима предмета, тужилац је своје потраживање према туженој покушао да реализује поред уговора о кредиту за обртна средства и наплатом менице као средством обезбеђења предметног уговора о кредиту, а како је меницу својеручно попунила тужена која ту чињеницу у току поступка није оспорила, то ће првостепени суд у поновном поступку утврдити да ли постоји могућност да је тужена одговорна за измирење преузетих обавеза у смислу чл. 46. ст. 1. Закона о меници, која одредба прописује да сви они који су меницу трасирали, акцептирали, индосирали или авалирали одговарају имаоцу менице.

Имајући у виду напред наведено, за сада се не може прихватити као правилан закључак првостепеног суда да нема одговорности тужене, према тужиоцу.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 22Гж. 649/13 од 26.03.2013. године)

Приредио: Миомир Митровић, судија Апелационог суда у Нишу
и Сандра Стефановић, судијски помоћник

ПРЕКИД ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА

Опоменом за испуњење обавезе, послате путем мејла, при чему није било признања дуга, дужник се само може позвати на испуњење обавезе, што у смислу одредбе чл. 391. Закона о облигационим односима није довољно за прекид застаревања.

Из образложења:

Одредбом чл. 391. Закона о облигационим односима предвиђено је да за прекид застаревања није довољно да поверилац позове дужника писмено или усмено да обавезу испуни.

У конкретном случају тиме што је тужилац поднеском од 26.02.2008. године, послатим путем мејла, опоменуо туженог на испуњење обавезе за период од 22.11.2006. године до 23.02.2008. године, при чему није било признања дуга од стране туженог, тужилац је само могао позвати туженог на испуњење обавезе, што у смислу напред цитиране законске одредбе није довољно за прекид застаревања.

(Пресуда Вишег суда у Нишу 5П4- 5/11 од 18.05.2012. године решење Апелационог суда у Нишу 16Гж-1666/12 од 13.09.2012. године)

Приредиле: Данијела Николић, судија
и Милена Симоновић, виши судијски сарадник

СОЛИДАРНО ЈЕМСТВО

(Члан 1002. ст. 2. и члан 1004. ст. 3. Закона о облигационим односима)

Уколико се уговором о јемству, јемац обавезао као јемац платаци онда он одговара повериоцу-банци као главни дужник-корисник кредита за целу обавезу и поверилац-банка може захтевати њено испуњење, било од главног дужника- корисника кредита, било од јемца, или од обојице истовремено.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању тужиоци су са туженом закључили уговоре о јемству, ради обезбеђења уговора о кредитима. Наведеним уговорима о јемству тужиоци су се обавезали да као јемци платци одговарају за целу обавезу као главни дужник, целокупном својом имовином. Овластили су и тужену да може своја доспела потраживања из уговора о кредиту, у случају да дужници закасне са плаћањем рате наплатити аутоматски са свих рачуна јемца, а уколико на рачуну нема довољно средстава да може своје потраживање наплатити из целокупне имовине јемца. Из налаза и мишљења вештака утврђено је да је тужена наплатила своје потраживање од тужилаца обустављањем од зараде, а на основу напред наведених уговора у износима ближе означеним у налазу. Предметни кредити нису наплаћени од корисника кредита нити од осигуравајуће куће. Исти нису отплаћени, већ је само извршено рачуноводствено евидентира-

ње гашења отписом, али не у смислу гашења обавеза клијената и њихових жираната.

На овако утврђено чињенично стање правилно је првостепени суд применио материјално право када је одбио захтев тужиоца, налазећи да нису испуњени услови из чл. 210. ЗОО.

Наиме, тужена је принудну обуставу од зарада тужилаца извршила у складу са наведеним уговорима о јемству, те је у конкретном случају постојао правни основ и тужена није дужна да наведена новчана средства врати тужиоцима.

Како су се у конкретном случају тужиоци писменим уговором о јемству обавезали као јемци платци, то је тужена као поверилац била овлашћена да захтева испуњење било од главних дужника-корисника кредита или од јемаца, овде тужилаца или од обојице истовремено. Имајући у виду да се ради о солидарном јемству то су неосновани наводи у жалби тужилаца да је тужена била у обавези да најпре изврши покушај наплате од потписника уговора о кредиту, а потом од јемаца.

Без утицаја су наводи у жалби да су кредити наплаћени од осигуравајуће куће из разлога што наведеном полисом осигурања није предвиђено осигурање нити једног конкретног кредита унапред, већ су осигурани сви случајеви који за последицу могу имати: незаконито пословање радника, фалсификовање хартија од вредности, изнуђивање итд. Наступање осигураног случаја цени сама осигуравајућа кућа, а не тужена. Уговор о осигурању представља правни однос тужене и осигуравајуће куће и исти је без утицаја на правни однос тужене банке и њених клијената по основу појединачних уговора. Износ који је банка наплатила од осигуравајуће куће представља штету коју је тужена имала због незаконитог пословања појединих запослених и то за све случајеве које је осигуравајућа кућа проценила да потпадају под осигурани случај до висине осигуране суме, те наплата наведеног износа не утиче на обавезу враћања кредита од стране тужилаца.

(Пресуда Основног суда у Врању П-1943/10 од 24.08.2012. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 16Гж-2707/12 од 17.01.2013. године)

Приредиле: Данијела Николић, судија
и Милена Симоновић, виши судијски сарадник

АУТОРСКИ УГОВОР

Усмено закључени ауторски уговор може производити правно дејство, али само као уговор о делу уколико је доказан садржај уговора, права и обавезе уговорних страна који из њега произилазе.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању тужилац је по усменом договору са бившим директором тужене Ц.Ц., насликао мурале у пословном простору тужене, у холу. Мурали су прекречени по налогу нове управе, директорке, јер су били оштећени услед влаге. Материјал за израду мурала обезбедила је тужена. Мурале је насликао тужилац крајем 2008. године, а студенти са Академије, на којој ради као професор, том приликом су му само помагали. Накнада за рад на муралима није уговорена, већ је договор био да тужилац наслика мурале и поклони их туженој.

На овако утврђено чињенично стање правилно је првостепени суд применио материјално право када је одбио захтев тужиоца и нашао да тужиоцу не припада право на накнаду нематеријалне штете.

Одредбом чл. 65. ст. 3. Закона о ауторским и сродним правима који је важио у време настанка спорног односа између парничних странака („Службени лист СЦГ“, бр. 61/2004) прописано је да се ауторски уговори закључују у писаној форми, ако овим законом није другачије одређено, а ставом 2. да се на ауторски уговор примењују одредбе закона којим се уређују облигациони односи, ако одредбама овог закона није другачије одређено.

У конкретном случају између парничних странака је закључен усмени ауторски уговор, који производи правно дејство, и то као уговор о делу, јер је доказан садржај уговора, права и обавезе уговорних страна који из њега произилазе, па се имају применити одредбе Закона о облигационим односима које се односе на уговор о делу из чл. 600. наведеног закона.

Наведеном законском одредбом је прописано да се уговором о делу посленик обавезује да обави одређени посао, као што је израда или оправка неке ствари или извршење неког физичког или интелектуалног рада и сл., а наручилац се обавезује да му за то плати накнаду. Имајући у виду наведену законску одредбу тужилац је једино од туженог могао захтевати накнаду за физички и интелектуални рад који је извршио, али ова накнада између стра-

нака није уговорена, а намера тужиоца је била да мурале поклони туженој, пе се у конкретном случају ради о доброделином правном послу.

По оцени Апелационог суда, тужилац нема право да од туженог потражује накнаду нематеријалне штете због повреде моралних ауторских права, па ни права из чл.17.и 18. Закона о ауторским и сродним правима, с обзиром на то да са туженом није закључио писани ауторски уговор, а како је то предвиђено чл. 65. ст. 3. истог закона, из кога би проистекло ово право, већ је закључио усмени уговор, који има правно дејство уговора о делу. Наиме, усмено закључени ауторски уговор може производити правно дејство, али само као уговор о делу, па како је у овој правној ствари првостепени суд правилно утврдио садржај, као и права и обавезе који из овог уговора произилазе, то се у овом случају морају применити одредбе Закона о облигационим односима, а не одредбе Закона о ауторским и сродним правима.

Како уништење материјалне ствари, па и уметничког дела, у конкретном случају мурала, не представља Законом о облигационим односима признати правни основ за досуђење нематеријалне штете проузроковане душевним патњама тужиоца насталим тим поводом, то је правилно одбијен његов тужбени захтев за накнаду овог вида штете.

(Пресуда Вишег суда у Нишу 4П4-4/11 од 17.07.2012. године; пресуда Апелационог суда у Нишу 16Гж-2145/12 од 01.11.2012. године)

Приредиле: Данијела Николић, судија
и Милена Симоновић, виши судијски сарадник

СТВАРНО ПРАВО

РЕЦИПРОЦИТЕТ КАО УСЛОВ ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА СВОЈИНЕ СТРАНИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА НА СТАНУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Да би страни држављанин могао стећи право својине на стану у нашој држави по основу закљученог уговора о доживотном издржавању, потребно је да је имао држављанинство Републике Србије у време закључења овог уговора или да постоји реципроцитет у поступању држава што значи да је то право под истим условима признато и нашим држављанима у држави чији је он држављанин.

Из образложења:

Према чињеничном стању утврђеном у поступку, тужила Х.В. држављанка Републике Бугарске и сада пок. М.М. закључили су уговор о доживотном издржавању у својству даваоца издржавања, са сада пок. А.М. дана 19.08.2004. године, којим су се обавезали да пруже услуге издржавања примаоцу издржавања с тим да на име накнаде, након његове смрти, стекну у својину по $\frac{1}{2}$ идеалних делова непокретности у П. у ул. Б.К., ближе означених изреком одлуке. У поступку расправљања заоставштине иза смрти примаоца издржавања А.М., сада пок. М.М. оглашен је за јединог законског наследника решењем о наслеђивању Општинског суда у Пироту од 28.2.2006. године на целокупној имовини која је била предмет уговора о доживотном издржавању, будући да у току поступка исти није пријавио предметни уговор. Такође, увидом у списе предмета утврђено је да је сада пок. М.М., као наследник свог пок. оца А.М., покренуо поступак у предмету ради раскида уговора о доживотном издржавању између тужиле и примаоца издржавања, али је овај поступак прекинут услед смрти М.М.

Код овако утврђеног чињеничног стања првостепени суд је усвојио тужбени захтев, налазећи да је тужила постала власник предметне непокретности у делу од $\frac{1}{2}$ идеалне, по основу закљученог уговора о доживотном издржавању, који иако је покренут поступак пред судом, није раскинут нити поништен.

По налажењу овог суда, наведени закључак првостепеног суда се за сада не може прихватити, јер у досадашњем поступку нису утврђене све релевантне чињенице од којих зависи правилна примена материјалног права.

За стицање права својине уговором о доживотном издржавању поред посебних услова предвиђених Законом о наслеђивању, морају бити испуњени и други, општи услови предвиђени Законом о основама својинско правних односа. Сходно чл. 82а Закона о основама својинско правних односа, страна физичка лица могу под условом реципроцитета стицати право својине на стану као и држављани Републике Србије. Дакле, да би тужилца могла стећи право својине на стану по основу закљученог уговора о доживотном издржавању, потребно је да је имала држављанство Републике Србије у време закључења овог уговора или да постоји реципроцитет у поступању држава што значи да је то право под истим условима признато и нашим држављанима у Републици Бугарској, чији је држављанин тужилца, коју чињеницу првостепени суд током поступка није утврђивао. Такође, сходно чл. 82в ЗОСПО, уговор о стицању права својине на непокретности може се оверити само ако су испуњени услови за стицање права својине из чл. 82а наведеног закона, што дакле значи само у случају када постоји узајамност у поступању државе чији је држављанин лице које уговором стиче право својине на стану или стамбеној згради на територији наше државе. У конкретном случају нејасно је да ли су били испуњени услови из чл. 82а ЗОСПО, да ли је тужилца имала држављанство Републике Србије у моменту закључења уговора о доживотном издржавању, односно у случају да није имала држављанство наше државе, да ли постоји узајамност у поступању републике Бугарске чији је држављанин, када је у питању стицање својине држављана Републике Србије на стану и непокретностима које се налазе у Републици Бугарској. Утврђења ове чињенице – постојање реципроцитета, је од битног значаја за оцену пуноважности закљученог уговора, јер уколико тужилца није имала држављанство Републике Србије и уколико не постоји реципроцитет у поступању са Републиком Бугарском, онда је закључени уговор супротан принудним прописима и то одредби чл. 82а ст. 2. ЗОСПО која као услов за стицање права својине стану и стамбеној згради страног физичког лица које не обавља делатност у Републици Србији, предвиђа постојање узајамности и противан чл. 82в којим је прописно да се уговор о стицању права својине на непокретности у смислу чл. 82а, овог закона, може оверити ако су испуњени услови за стицање права својине из тог члана.

Имајући у виду да је предметни уговор о доживотном издржавању оверен пред Општинским судом у Пироту под бројем III Р.бр.444/04 дана

19.08.2004. године, у поновном поступку првостепени суд ће утврдити да ли су били испуњени услови за закључење и оверу овог уговора пред судом, прописани чл. 82а и 82в ЗОСПО, те да ли је овера пред судом извршена супротно наведеним принудним прописима и сходно томе да ли је уговор ништав у смислу чл. 103. ЗОО.

Приликом утврђивања да ли постоји узајамност, као услов за стицање права својине држављана Бугарске на стану и стамбеној згради у Републици Србији, првостепени суд може објашњење о томе затражити од Министарства правде сходно чл. 82в ст. 2. и 3. Закона о основама својинско правних односа.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж.208/13)

Аутор сенценце: Слађана Ђуричковић, судија
и Бети Лазаревић, судијски помоћник

ПРЕМЕСТАЊЕ ПРАВЦА СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА

Власник повласног добра има право на одговарајуће премештање правца службености пролаза, сходно измењеним околностима, насталим накнадним грађењем.

Из образложења:

Тужилац је право сезонске службености имао кроз средину парцеле туженог кп. 250/2 за долазак до своје парцеле кп. 260, које право му тужени није оспоравао. Изградњом куће и помоћних објеката, тужени је сам изместио ову службеност, те је трећим лицима, признао право проласка преко његове парцеле али другом трасом, како је то предвиђено поравнањем које је тужени закључио са трећим лицима у предмету Општинског суда у Сурдулици П-204/95, а које право не спори и тужиоцу. Међутим, како би тужилац дошао до своје парцеле - повласног добра то мора пролазити преко овог неспорног дела парцеле, потом да скрене под углом од деведесет степени у правцу истока преко исте парцеле туженог или да пролази преко парцела трећих лица кп. 251 и кп. 259, преко којих никада није пролазио и није стекао право пролаза ни по ком основу.

По оцени Апелационог суда у складу је са одредбом чл. 50. Закона о основама својинско правних односа премештање правца стварне службености на правац којим власник послужног добра - тужени, трпи најмање оптерећење, под условом да се власник повласног добра - тужилац, пре-

мештањем правца службености не стави у положај којим би његово право на вршење службености било знатно отежано.

У конкретној правној ствари испуњени су услови за премештање правца стварне службености, јер је до градње куће и помоћних објеката туженог, тужилац пролазио средином послужне парцеле, а тужени му то право није оспоравао. Како је изградњом куће и помоћних објеката тужени онемогућио вршење права службености пролаза тужиоца, то власник повласног добра - тужилац, има право на одговарајуће премештање правца службености пролаза, у мерама и границама које су утврђене налазом вештака, а сходно измењеним околностима, насталим грађењем.

Како тужени спречава тужиоца у вршењу стварне службености, то су испуњени услови из чл.57. Закона о основана својинско правних односа за заштиту овог тужиоцевог права па је тужени обавезан да уклони са спорног простора ограду од бодљикаве жице и омогући тужиоцу коришћење права сезонске службености пролаза.

(Пресуда Основног суда у Врању – Судска јединица у Сурдулици V-13 П. 3988/10 од 06.02.2012. године; пресуда Апелационог суда у Нишу 16Гж-1169/12 од 31.05.2012.године)

Приредиле: Данијела Николић, судија
и Милена Симоновић, виши судијски сарадник

СТВАРНА СЛУЖБЕНОСТ

Стварна службеност представља правни однос између власника двеју непокретности. Из правне природе службености произлази да се службеност односи само на туђу ствар. Нема службености на власти тој ствари (*nemini res sua servit*). За постојање службености потребно је да повласно и послужно добро припадају различитим лицима. (Међусобни односи сувласника у оваквим случајевима уређују се у поступку заједничког коришћења).

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужила и тужена су рођене сестре, које су након смрти родитеља наследили њихову имовину. Између остале имовине наследили су и породичну кућу у селу. Такође је утврђено и то да су странке су-

власнице предметне породичне зграде и исту користе тако да свака од њих има по једну собу на спратном делу куће а улазни део-ходник заједнички користе.

Тужбеним захтевом тужила је тражила да се утврди да је тужена заклачувањем и променом браве на улазним вратима узурпирала установљено право службености пролаза и просторија које припадају тужили те да се туженој наложи да се уздржава у повреди права службености пролаза и улаза у заједничке просторије.

Одредбом чл. 49. Закона о основама својинско правних односа, прописано је да је стварна службеност, право власника једне непокретности (повласно добро), да за потребе те непокретности врши одређене радње на непокретности другог власника (послужно добро) или да захтева од власника послужног добра да се уздржава од вршења одређених радњи које је иначе имао право да врши на својој непокретности.

Из напред цитиране законске одредбе произлази да је службеност стварно право на туђој ствари које овлашћује титулара да ту ствар непосредно и ограничено користи. Стварна службеност представља правни однос између власника двеју непокретности у коме је власник једне непокретности овлашћен да на одређен начин и у одређеној мери користи другу непокретност или да њеном власнику забрани да се њоме служи у одређеном правцу. Помоћу службености омогућава се власнику повласног добра боље коришћење туђег добра или преношење вишка користи са послужног на повласно добро у циљу поравнања између вишка користи и недостатка на другој страни.

Из правне природе службености произлази да се службеност односи само на туђу ствар, што значи да нема службености на властитој ствари. За постојање службености потребно је да повласно и послужно добро припадају различитим лицима. Стога тужила као сувласник предметне просторије није могла стећи право службености, јер се такво право може установити само на непокретности другог власника. Сувласничка просторија не може истовремено представљати повласно и послужно добро у смислу чл. 49. Закона о основама својинскоправних односа, те је погрешно првостепени суд приликом одлучивања о тужбеном захтеву применио одредбу чл. 49. Закона о основама својинскоправних односа.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 5Гж. 807/13 од 16.04.2013. године)

Приредила: Слађана Ђуричковић,
судија Апелационог суда у Нишу

ПОРОДИЧНО ПРАВО

ИЗДРЖАВАЊЕ РАЗВЕДЕНОГ СУПРУЖНИКА И КАРАКТЕР УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ПОРОДИЧНОГ ЗАКОНА

Одредба чл. 151. ст. 1. Породичног закона не предвиђа кумулативне услове који морају бити испуњени да би супружник остварио право на издржавање, па није потребно утврђивати неспособност за рад, у ситуацији када је утврђена незапосленост и недостатак средстава за издржавање.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, парничне странке су биле у браку пет година и немају деце, а брак је разведен пресудом Општинског суда у Прокупљу П. бр 2125/09 од 06.11.2009. године која је потврђена пресудом Апелационог суда у Нишу Гж2. 295/10 од 9.11.2010. године. Тужила у бракоразводном спору није поднела захтев за издржавање. Из приложене медицинске документације првостепени суд утврђује да се тужила јављала лекару почев од октобра 2009.године, да је у вишенаврата лечена од стране психијатра који јој је преписивао одређену терапију за тегобе које је имала, али да у извештајима лекара није наведено да се ради о тежој болести или поремећају. По оцени првостепеног суда, с обзиром на тегове констатоване у медицинској документацији, тужила може обављати одређене послове и живети од свог рада, а налази се у статусу незапосленог лица, што произилази из евиденције Националне службе за запошљавање. Тужени је запослен у Министарству одбране ВП 1097 Ниш и примања за август, септембар и октобар 2011. године су износила око 28.000,00 динара. Тужени је закључио нови брак из кога има малолетно дете. С обзиром на наведено првостепени суд је закључио да би усвајање тужбеног захтева тужиле за издржавање представљало очигледну неправду за туженог, у смислу члана 151. став 3. Породичног закона, с обзиром да она може да обавља одређене послове и од њих се издржава, јер су њене месечне потребе 16.000,00 динара.

У побијаној другостепеној пресуди наведено је да тужила није доказала да је радно неспособна, иако је на њој био терет доказивања у смислу члана 223. ЗПП, па је њен тужбени захтев правилно првостепени суд одбио као неснован, и оцењени су као неосновани жалбени наводи тужиле да је првостепени суд требало по службеној дужности да изведе доказ вештачењем ради утврђивања тужилине радне способности, будући да за ову чињеницу тужила није предложила нити пружила доказе.

По оцени Врховног касационог суда, ревизији тужиле основано се истиче да је побијана пресуда захваћена битном повредом поступка из члана 361. став 2. тачка 12. ЗПП, будући да има недостатака због којих се не може испитати и да је у нижестепеним пресудама због погрешне примене материјалног права чињенично стање остало непотпуно утврђено.

Према члану 205. ЗПП, у поступку у вези са породичним односима суд може утврђивати чињенице и када оне нису међу странкама, спорне, а може и самостално истраживати чињенице које ни једна странка није изнела.

Наведена законска одредба прописује примену истражног начела у споровима из породичних односа, што обавезује суд да изведе све потребне доказе и утврди релевантне чињенице за доношење одлуке о предмету спора, без обзира да ли су их странке изнеле или оспориле током поступка. Стога нижестепене пресуде нису могле бити засноване на примени правила о терету доказивања у смислу члана 223. ЗПП, нити је тужбени захтев тужиле могао бити одбијен из разлога што није доказала постојање битних чињеница од којих зависи њено право на издржавање.

У нижестепеним пресудама утврђено је да је брак парничних странака правноснажно разведен ранијом пресудом, и да тужила у бракоразводној парници није тражила издржавање. Међутим, нису утврђене битне чињенице које се односе на могућност подношења тужбе за издржавање након престанка брака, односно када је тужили учињено последње фактичко давање на име издржавања, те а ли постоји оправдан разлог због кога није поднела тужбу за издржавање у брачном спору, уз смислу члана 279. став 3. Породичног закона.

Такође, није правилно примењен члан 151. став 1. Породичног закона, будући да ова законска одредба не предвиђа кумулативне услове који морају бити испуњени да би супружник остварио право на издржавање,

па није потребно утврдити и тужилину неспособност за рад, у ситуацији када је утврђено да је незапослена и нема довољно средстава за издржавање. Да би се правилно оценило да ли би тужилин захтев за издржавање представљао очигледну неправду за туженог, у смислу члана 151. став 3. Породичног закона, потребно је утврдити потребе повериоца и могућности дужника издржавања, у смислу члана 160. овог закона. Будући да у нижестепеном поступку нису утврђене наведене битне чињенице од којих зависи правилна примена материјалног права, обе нижестепене пресуде су укинуте.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж2. 102/12 од 19.04.2012. године и решење Врховног касационог суда Рев. 7709/2012 од 30.09.2012. године)

Аутор сенценце:
судија Миомир Митровић

ПРАВО СТАНОВАЊА И АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

Разведени супружник не може самостално захтевати заснивање права становања на стану у власништву бившег супружника.

Родитељ који врши родитељско право над дететом своје право становања црпи из права детета и то до његовог пунолетства.

Из образложења:

Према чињеничном стању на коме је заснована побијана одлука, парничне странке су бивши супружници, чији брак је разведен правноснажном судском одлуком од 17.4.2007. године, којом су деца странака, кћи С.Ц. рођена 5.8.1994. године и син С.Ц. рођен 23.1.1998. године, поверени на самостално вршење родитељског права тужили - мајци те њих троје (након развода брака парничних странака) живе у стану у Нишу, на коме тужила тражи утврђење права становања, а чији је власник тужени, по основу уговора о поклону, који је закључио са својом мајком као поклонодавцем. Тужени се из наведеног стана иселио, а по разводу брака са тужиљом закључио је други брак у коме има малолетно дете, а са новом породицом живи у Земуну, у изнајмљеном стану. Судови су утврдили да је тужила ванкњижни власник стана површине 37,84 м² који се налази у Ни-

шу, у улици К. број 103/4 у високом приземљу, по основу уговора о купо-продаји са Д.С. из Ниша, као продавцем, а утврдили су и да је тужила током 2007. године продала: стан који се налази у Блацу, у улици К. број 173/3, површине 60,36 м², као и непокретност у Блацу, са породичном стамбеном зградом од слабог материјала, површине 80 м².

Код овако утврђеног чињеничног стања, нижестепени судови су одбили тужбени захтев налазећи да тужила има право својине на усељивом стану, због чега је искључено њено стицање права становања на предметном стану, чији је власник тужени, применом чл. 194. ст. 1. Породичног закона.

Врховни касациони суд који није везан разлозима на којима нижестепени судови заснивају своју одлуку, налази да је правилан закључак судова да је тужбени захтев неоснован, али из разлога што тужила као разведени супружник не може самостално захтевати заснивање права становања на стану у власништву бившег супруга, применом члана 194. Породичног закона.

Наиме, одредба члана 194. Породичног закона, ("Службени гласник РС", број 18/05), прописује да дете и родитељ који врши родитељско право имају право становања на стану чији је власник други родитељ детета, ако дете и родитељ који врше родитељско право немају право својине на усељивом стану (став 1. овог члана) а право становања траје до пунолетства детета (став 2. истог члана).

Из наведене законске одредбе произлази да изворно право становања има дете, а родитељ који врши родитељско право над дететом, своје право становања црпи из права детета и то до његовог пунолетства. То даље значи да родитељ који самостално врши родитељско право над малолетним дететом, не може поднети самосталну тужбу којом се тражи утврђење права становања само у своју корист (у корист родитеља) јер наведена законска одредба штити право становања малолетног детета, а не родитеља који над дететом самостално врши родитељско право.

Одредбом члана 263. став 1. Породичног закона која прописује да тужбу за заштиту права детета може поднети дете, родитељ детета, јавни тужилац и орган старатељства, у овим споровима, па самим тим ни у спору за утврђење права становања малолетног детета на стану чији је власник родитељ са којим дете не живи, не предвиђа нужну супарничарску

заједницу на начин како то чини члан 256. истог закона, због чега суд не може одбацити тужбу као неуредну уколико дете није означено као странка ус пору. међутим, приликом одлучивања мора се имати у виду материјална одредба по којој је право становања (применом члана 194. став 1. Закона) право детета, док родитељ који са дететом живи, има право становања на стану у власништву бившег супружника, само док врши самостално право над малолетним дететом и то до његовог пунолетства, односно његово право није самостално, већ је изведено из права детета и постоји само до момента до ког и дете има право да га остварује.

Имајући у виду изнето, односно да тужиља као разведени супружник не може самостално засновати право становања на стану чији је власник тужени, бивши супруг, то Врховни касациони суд налази да из ових разлога тужбени захтев није основан.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж2. 272/12 од 03.10.2012. године и пресуда Врховног касационог суда Рев. 263/2013 од 13.03.2013. године)

Аутор сентенце:
судија Миомир Митровић

НАСЛЕДНО ПРАВО

УРАЧУНАВАЊЕ ПОКЛОНА У НАСЛЕДНИ ДЕО

Захтев за урачунавање поклона у наследни део може се са успехом истицати само до правноснажног окончања оставинског поступка, па уколико се такав захтев не истакне у оставинском поступку, онда наследник не може у посебној парници, по правноснажном окончаном оставинском поступку, тражити да се утврди да је неко од наследника измирен у свом наследном делу, односно захтевати да се у наследни део законском наследнику урачунавају поклони добијени од оставиоца.

Из образложења:

У оставинском поступку пок. Н.Т. одбачен је као неблаговремен захтев учесника Н.Н. за урачунавање поклона - зграде бр. 28 у ул. П.П. у наследни део наследницима Н.М. и В.М. На ово решење учесник Н.Н. уложила је жалбу о којој није одлучено до закључења главне расправе.

Како пок. Т.Д. није у самом уговору о поклону, нити касније изјавио да се поклон неће урачунати наследницима у њихов наследни део, нити постоје околности из којих се може закључити да је то била намера оставиоца, суд је усвојио тужебни захтев тужиље Н.Н. и утврдио да се у наследни део наследницима Н.М. и В.М. има урачунати поклон оставиоца, по основу уговора о поклону овереним пред Општинским судом у Нишу, а којим је тужиоцу-противтуженом Н.М. и туженој В.М., као поклонопримцима, поклонιο и то сваком по $\frac{1}{2}$ поменуте стамбене зграде, а како је то ближе наведено у самом уговору о поклону.

Првостепени суд сматра да је у конкретном без правне важности то што је у оставинском поступку иза смрти пок. Т.Д. одбачен као неблаговремен захтев овде тужене Н.Н. за урачунавање поклона овде тужиоцу Н.М. и туженој В.М., и то што по жалби на ово решење није донета одлука.

Овакав став првостепеног суда је неприхватљив, јер се захтев за урачунавање поклона у наследни део може са успехом истицати само до правноснажног окончања оставинског поступка. Ако се овакав захтев не истакне у оставинском поступку, онда наследник не може у посебној парници, по правноснажном окончаном оставинском поступку, тражити да се утврди да је неко од наследника измирен у свом наследном делу, односно захтевати да се у наследни део законском наследнику урачунавају поклони добијени од оставиоца. О захтеву за урачунавање одлучује се у току поступка за расправљање заоставштине, како је то прописано одредбама чл. 66. и 69. Закона о наслеђивању. Тек ако у том поступку дође до одређеног спора, прекинуће се оставински поступак и на парницу упутити учесник у чијем је интересу да се поклон урачуна у наследни део другог учесника.

Из тог разлога ће првостепени суд у поновном поступку оценити да ли су испуњени услови за понављање оставинског поступка према правилима парничног поступка, имајући у виду да је тужила НН у току поступка истакла да је сазнала за поменути уговор о поклону тек након 8 година од закључења истог, као и да ли је захтев за урачунавање поклона у наследни део истакнут до правноснажног окончања оставинског поступка, па ће уз правилну примену материјалног права донети нову одлуку у којој ће дати разлоге о свим одлучним чињеницама.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу, 13 Гж.560/12 од 19.04.2012. године)

Приредили: Миодраг Марјановић, судија
и Јелена Увалин, судијски помоћник

НЕПОСТОЈАЊЕ АЛЕАТОРНОСТИ КОД УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

Не може се сматрати да је незаконит и неморалан уговор о доживотном издржавању коме недостаје елемент алеаторности, јер је била извесна смрт примаоца издржавања у кратком року, што је било познато даваоцу издржавања, у случају када је до стварног издржавања дошло.

Из образложења:

Према чињеничном стању утврђеном у поступку, тужени је са својим оцем, сада пок. Д.С., закључио уговор о доживотном издржавању оверен пред Основним судом у Лесковцу, дана 26.10.2010. године. Из provedених доказа утврђено је да се је сада пок. Д.С. разболео априла месеца 2009. године од тешке болести карцинома плућа од које је 13.11.2010. преминуо, што је 17 дана након што је са својим сином, туженим Н.С., закључио уговор о доживотном издржавању. Из исказа саслушаних сведока утврђено је да је тужени са својом породицом живео у Лесковцу, али да је често, готово свакодневно посећивао родитеље, те је и пре закључења уговора о доживотном издржавању помагао родитељима тако што је обрађивао имање, водио сада пок. Д.С. лекару, набављао лекове, давао новац за измирење дуга по основу утрошене електричне енергије, да се и његова супруга старала о његовим родитељима и помагала им у чишћењу и одржавању куће при чему је између њих успостављена и заједница живота неколико месеци пре смрти примаоца издржавања.

Код овако утврђеног чињеничног стања правилно је првостепени суд одлучио, правилно примењујући материјално право, одредбе чл. 203 Закона о наслеђивању, када је одбио као неоснован тужбени захтев тужиоца за поништај уговора о доживотном издржавању, налазећи да у конкретном случају не стоје разлози за поништај прописани законом.

Уговор о доживотном издржавању коме недостаје елемент алеаторности, јер је била извесна смрт примаоца издржавања у кратком року, што је било познато примаоцу издржавања, није незаконит нити неморалан нарочито у ситуацији када је до стварног издржавања заиста дошло, као што је то у конкретном случају, где је тужени примаоцу издржавања и пре закључења уговора о доживотном издржавању пружао сву неопходну бригу и пажњу, помагао у пољопривредним радовима и у свакодневном одржавању домаћинства, неговао у болести, набављао лекове и водио код лекара и живео у истом домаћинству са примаоцем издржавања у времену када је услед болести, примаоцу била неопходна свака помоћ и подршка, те је правилан закључак првостепеног суда да сама чињеница да је прималац издржавања преминуо кратко време по закључењу уговора о доживотном издржавању, не указује на ништавост овог уговора.

Имајући у виду да је тужени пружао издржавање оцу у периоду пре наступања болести и за сво време њеног трајања, дакле и пре закључења

уговора као и за време трајања уговора, улажући повећани труд и бригу у лечењу тешко оболелог родитеља, то се жалбом неосновано истиче да је извесна смрт примаоца издржавања у кратком року након закључења уговора, била мотив за закључење уговора о доживотном издржавању од стране туженог и да због тога уговор треба поништити.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж.бр.631/13 од 23.04.2013. године)

Аутор сентенце: Слађана Ђуричковић, судија
и Бети Лазаревић, судијски помоћник

ВРАЋАЊЕ ПОКЛОНА

(Чл. 59. ст. 2. Закона о наслеђивању)

Рок из члана 59. ст. 2. Закона о наслеђивању односи се на застарелост тужбе, а не потраживања, те исти има карактер материјалног преклузивног рока, а не рока застарелости па се његовим пропуштањем губи право на тужбу и судску заштиту.

Из образложења:

Према чињеничном стању тужилац је отац туженом, тужени је са својим дедом сада пок. В.Ђ. који је умро 10.07.2005. године закључио уговор о доживотном издржавању оверен код Општинског суда у Лебану П.475/95 од 16.12.1995. године, а касније и уговор о поклону Ов-673/05 од 14.06.2005. године. Наведеним уговором о поклону тужени је добио у својину непокретности ближе означене у изреци пресуде јер је живео у заједници са пок. В.Ђ. и његовом супругом. Након смрти В.Ђ. вођен је оставински поступак који је најпре прекинут и тужилац упућен на парницу да докаже да су без правног дејства уговор о доживотном издржавању, као и уговор о поклону, а након тога прекинут је решењем О-278/08 од 17.07.2008. године и овде тужилац упућен на парницу јер у поднеску од 13.03.2008. године истакао да му је учињеним поклоном повређено право на нужни део. Тужбу ради редукције уговора о поклону тужилац је поднео 20.08.2008. године.

На основу овако утврђеног чињеничног стања првостепени суд је одбио тужбени захтев тужиоца јер је тужбу поднео по протеку рока из чл. 59. Закона о наслеђивању.

Овакав закључак првостепеног суда, Апелациони суд у Нишу за сада не може прихватити.

Наиме, одредбом чл. 59. ст. 2. Закона о наслеђивању је предвиђено да се враћање поклона може захтевати у року од три године од смрти оставиоачеве. Наведени рок односи се на застарелост тужбе, а не потраживања, те исти има карактер материјалног преклузивног рока, а не рока застарелости па се његовим пропуштањем губи право на тужбу и судску заштиту. О преклузивном року суд води рачуна по службеној дужности, а не по приговору туженог и о истом суд не одлучује мериторно већ решењем одбацује тужбу.

У конкретном случају, првостепени суд је донео пресуду којом одбија тужбени захтев, чиме је повредио одредбу чл. 59. Закона о наслеђивању ако је већ нашао да треба применити ту законску одредбу.

Одредба чл. 59. Закона о наслеђивању не односи се само на покретање парничног поступка, подношењем тужбе, тако да се не може занемарити захтев тужиоца истакнут у оставинском поступку у поднеску од 13.03.2008. године у коме је тужилац истакао да му је учињеним поклоном повређено право на нужни део и на рочишту од 17.06.2008. године, те је решењем О-278/08 од 17.07.2008. године упућен на парницу. Овако истакнут захтев има карактер тужбе у материјалном смислу, јер се њиме постиже исти циљ, враћање поклона због повреде нужног дела.

Због напред наведеног, првостепена пресуда је морала бити укинута и предмет враћен на поновно суђење. Правилна примена материјалног права захтева да првостепени суд приступи мериторном одлучивању, пошто није протекао рок из чл. 59. ст. 2. Закона о наслеђивању, јер је захтев за враћање поклона поднет у оставинском поступку, који је довео до упућивања тужиоца на ову парницу, а оставилац је умро 10.07.2005. године.

(Пресуда Основног суда у Лесковцу-Судска јединица у Лебану II 9П-1523/10 од 02.03.2010.године; решење Апелационог суда у Нишу 16Гж-1278/12 од 24.01.2013. године)

Приредиле: Данијела Николић, судија
и Милена Симоновић, виши судијски сарадник

РАДНО ПРАВО

Правно схватање поводом тужби судија за накнаду материјалне и нематеријалне штете

ЗАКЉУЧАК

са седнице одељења за радне спорове свих Апелационих судова одржане 17.05.2013. године у Апелационом суду у Нишу.

Када поступци по жалби нису окончани до ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о Уставном суду („Службени гласник РС" број 99/11 од 27.11.2011. године) процесна претпоставка за остваривање права судије на накнаду штете за период невршења судијске дужности до подношења жалбе, у парници је, да није за тај период захтевана иста накнада штете у жалби (објективно - субјективни идентитет).

Када је захтев за накнаду штете поднет Комисији из чл. 90. став 3. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС" број 109/07), до дана ступања на снагу назначених новела и тај орган прихватио надлежност, назначено питање решиће се у складу са прописима који су важили на дан ступања на снагу овог закона.

Пропуст судије да поднесе захтев Комисији из чл. 90. став 3. Закона о Уставном суду ("Службени гласник РС" број 109/07), до дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о Уставном суду („Службени гласник РС" број 99/11 од 27.11.2011. године) неће представљати процесну сметњу за парницу ради накнаде штете.

Постоји грађанско правна одговорност Републике Србије за наставак узорка штете судији чија је одлука о престанку судијске функције, односно одлука о приговору на ту одлуку поништена, а накнадно није донета одлука да судија испуњава законом прописане услове за избор на судијску функцију.

Mutatis mutandis исто важи када је одлуком Уставног суда наложена касација одлуке о престанку судијске функције, а Високи савет судства је у тој ситуацији искључиво донео одлуку о избору, а пропустио да изврши претходно касацију назначеног акта.

Материјална штета у виду изгубљене зараде одређује се према вредности плате суда који је преузео надлежност, или део надлежности суда у коме је судија до доношења одлуке о неизбору обављао судијску дужност умањене за вредност примљене накнаде по основу одредбе 101. Закона о судијама за период до 30.06.2010. године, као и за период после тога датума ако није извршен његов повраћај под условима из закона.

За случај да је стварна надлежност суда у коме је радио неизабрани судија до 31.12.2009. године подељена на два суда различите стварне надлежности код одмеравања накнаде штете по основу изгубљене зараде меродавна је узорна плата судије у односу на коју је донета одлука о његовом избору.

У вредност изгубљене зараде не урачунава се износ примљен по основу додатка за исхрану, накнаде за превоз и накнаде за годишњи одмор, као и додаци по основу дежурства.

Вредност накнаде штете треба сразмерно умањити за вредност зараде и других примања које је оштећени остварио или је могао остварити.

Судија има право на накнаду штете због повреде права на правично суђење, ако је повреда овог права утврђена Одлуком Уставног суда, а право на накнаду штете због повреде части и угледа зависи од околности сваког конкретног случаја.

Приредио: Зоран Ђорђевић, судија
председник одељења за радне спорове
Апелационог суда у Нишу

ПОВЕРИЛАЧКА ДОЦЊА

(Чл. 325. и 326. ЗОО)

Када дужник понуди испуњење изворне доспеле обавезе и свих обавеза које су последица доцње, а поверилац без основаног разлога одбије да прими испуњење или га својим понашањем спречи, тада поверилац долази у доцњу и од тог дана престаје тећи камата на главницу коју дужник дугује, сходно чл. 326. ст. 1. и 2. ЗОО.

Из образложења:

У току поступка, у датом одговору на тужбу, тужени је основано истицао да је тужба у погледу чињеничног основа који је постојао у то време, иста преурањена, јер коначна одлука о нераспоређеној добити није донета, те да је у Одлуци од 16.02.2006. године, на којој је заснован тужбени захтев, утврђено је да се вредност обавезе конвертује у капитал, који може бити конвертован у акције, што је и спроведено, а што несумњиво произилази из касније донетих одлука друштвеног предузећа од 26.11.2007. године који је био у поступку приватизације, а којом се у тач. 9. Одлуке, утврђује да ће се извршити брисање уписа повећања капитала у означеном износу и уписане забележбе у Регистру привредних субјеката пред Агенцијом за привредне регистре РС, а тачком 12. исте Одлуке, предвиђено је да та одлука ступа на снагу по добијању сагласности Агенције за приватизацију.

Како је реализована конверзија потраживања запослених у основни капитал, у смислу Одлуке од 16.02.2006. године, то потраживање тужилаца у виду нераспоређене добити, сходно ст. 3. Одлуке, није било доспело, јер је било условљено тиме да се обавеза не конвертује у акције.

Агенција за приватизацију решењем од 10.04.2008. године, дала је сагласност са обавезом да се изврши брисање повећања капитала и забележбе у Регистру привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, а затим је донета Одлука од 17.4.2008. године, којом је допуњена Одлука од 26.11.2007. године, тако да је утврђена обавеза предузећа да се запосленима исплати нераспоређена добит, услед чега је правилна закључак првостепеног суда да тражено новчано потраживање није доспело доношењем одлуке 16.02.2006. године, нити доношењем одлуке од 26.11.2007. године, при том нарочито имајући у виду напред наведену од-

редбу чл. 12. Одлуке од 26.11.2007. године, која у законом предвиђеном поступку није оспоравана.

Пошто су обезбеђена средства и утврђен начин и методологија исплате нераспоређене добити, у смислу донетог Закључка Владе Републике Србије од 30.10.2008. године, послодавац је понудио тужиоцу закључење споразума 12.11.2008. године, у погледу исплате предметног новчаног потраживања, који тужилац није прихватио, што је неспорно међу странкама и што несумњиво произилази из поднеска тужиоца којим управо не прихвата понуђену исплату, заснивајући свој захтев на одлуци Управног одбора која је донета у 2006. години, на основу које новчано потраживење није доспело и која је одлуком Управног одбора од 27.11.2007. године стављена ван снаге, при том без указивања да је покретан поступак оцене законитости Одлуке од 16.02.2006. године и последица које је та одлука произвела, као и Одлуке од 26.11.2007. године. Из изнетих разлога, Апелациони суд налази да је правилан закључак првостепеног суда, да је тужилац пао у поверилачку доцњу.

Поверилачка доцња, сходно чл. 325. ст. 1. ЗОО, представља случај када поверилац пада у доцњу, јер без основаног разлога одбија пријем испуњења од стране дужника или га својим понашањем спречава да испуни обавезу. Дужник нема могућности да повериоца принудним путем нагна на сарадњу, али законодавац прописује да ће поверилац који неоправдано не прихвати испуњење, сносити због тога извесне последице. Отуда и постоји институт поверилачке доцње која не представља кршење обавезе, али рађа извесне последице за повериоца и дужника. Поверилац долази у доцњу када се испуне услови и то уколико се ради о доспелој дужничкој обавези, да је понуда учињена и да је поверилац неосновано одбио понуду.

Понуда дужника да испуни обавезу је уједно и апел дужника да поверилац прихвати испуњење. Понуда мора да се поклапа са садржином повериоачевог потраживања, дакле мора бити понуђено давање онога што се дугује и како се дугује. Понуда такође, мора бити стварна и реална, да је дужник предузео све што је потребно за испуњење, тако да је повериоцу остало само да чинидбу прихвати.

Ако је у питању новчани дуг, а дужник је запао у доцњу, мора поред главнице понудити и исплату камате. Дужник може понудити и делимично испуњење новчане обавезе, осим ако поверилац има оправдани инте-

рес да га одбије. Понуду мора учинити сам дужник или треће лице које је на то овлашћено и то повериоцу који прима предмет обавезе. Доласком повериоца у доцњу престаје доцња дужника. Дакле, ако је дужник запао у доцњу и понуди испуњење изворне обавезе и свих обавеза које су последица доцње, као у конкретном случају, повериочева доцња искључује доцњу дужника и од тог тренутка престаје тећи камата на главницу коју дужник дугује сходно чл. 326. ст. 1. и 2. ЗОО.

Право дужника и његова могућност је и да депонује средства у поступку пред надлежним судом у ком случају се дужник ослобађа обавезе исплате, односно сматра се да је испунио своју обавезу, што у конкретном случају не стоји, јер на тај начин у смислу чл. 327. и 331. ЗОО, тужени није поступио.

Стога, тужени и даље има обавезу да исплати тражено новчано потраживање, али како тужилац није доказао основаност разлога због којег је одбио испуњење, и фактички својим понашањем спречио је туженог да своју обавезу испуни, то је наступила поверилачка доцња, услед чега је правилан закључак првостепеног суда да део прецизираног тужбеног захтева, у односу на обавезу туженог да тужиоцу исплати законску затезну камату није основан, обзиром да новчано потраживање још увек није било доспело, а након доношења наведених одлука и закључака, ток исплате законске затезне камате је прекинут одбијањем понуде туженог да тужиоцу исплати учешће у добити.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, 18Гж1.1233/13 од 24.05.2013. године)

Аутор сентенце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу

НАДЛЕЖНОСТ СУДА У СПОРУ ПОВОДОМ РАЗРЕШЕЊА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ

(Чл. 22. и 23. Закона о уређењу судова - „Сл. гласник РС“, бр. 116/08)

За поступање у спору ради поништаја одлуке оснивача о разрешењу директора установе, стварно надлежан је Виши суд, у складу са

одредбом чл. 23. ст. 1. тач. 8. Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/08 са изменама и допунама).

Из образложења:

Апелациони суд у Нишу је решавајући настали сукоб стварне надлежности на основу одредбе чл. 22. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/11) и чл. 15. и 24. Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/08 са изменама и допунама) нашао да је за поступање у овом предмету стварно надлежан Виши суд у Нишу.

Одредбом чл. 23. ст. 1. тач. 8. Закона о уређењу судова, прописано је да је Виши суд у првом степену суди у споровима поводом штрајка, поводом колективних уговора ако спор није решен пред арбитражом, поводом обавезног социјалног осигурања ако није надлежан други суд, поводом матичне евиденције, поводом избора и разрешења органа правних лица ако није надлежан други суд. Према одредби чл. 22. ст. 3. истог закона, Основни суд у првом степену суди у стамбеним споровима, споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа, о правима, обавезама и одговорностима из радног односа, о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом, споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.

У конкретном случају, тужбеним захтевом тражен је поништај одлуке о разрешењу органа правног лица, решења Скупштине општине Алексинац бр. 020/20 од 14.02.2012. године, које је донето на основу овлашћења прописаних чл. 52. тач. 10. Статута тужене и одредбом чл. 18. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр.42/91...79/05) којом је предвиђено да директора установе именује и разрешава оснивач. Директор је орган установе (чл. 16.) који руководи установом, а установа има својство правног лица (чл. 15.). Одредбом чл. 48. Закона о раду уређен је положај директора који након донете одлуке о именовању, заснива радни однос уговором о раду или закључењем уговора о међусобним правима, обавезама и одговорностима. С тим у вези и одлука о разрешењу може бити основ за доношење одлуке о престанку радног односа. Дакле, одлука оснивача о разрешењу директора и одлука послодавца о престанку радног односа су два потпуно различита појединачна акта, са различитим дејством, из којих разлога се не може прихватити становиште Вишег суда да се у конкретном случају ради о спору поводом заснивања, постојања и

престанка радног односа и да је у смислу чл. 22. ст. 3. Закона о уређењу судова надлежан Основни суд.

(Из решења Апелационог суда у Нишу, 18 Р1. 130/13 од 26.04.2013. године)

Аутор сентенце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу

ПРОЦЕСНА КАМАТА

(Чл. 279. ст. 2. у вези чл. 295. ст. 2. ЗОО)

Када је главно потраживање исплаћено у доцњи, поверилац стиче право да износ неисплаћене законске камате, остварује као самостално потраживање у обрачунатом износу, од дана доспелости главног потраживања, до дана исплате, у смислу чл. 295. ст. 2. ЗОО, са правом на исплату процесне камате, од дана када је суду поднет захтев за њену исплату, сходно чл. 279. ст. 2. ЗОО.

Из образложења:

Одредбом чл. 110. ст. 1. Закона о раду прописано је да се зарада исплаћује у роковима утврђеним општим актом и уговором о раду, најмање једанпут месечно, а најкасније до краја текућег месеца, за претходни месец. Дакле, рокови и динамика исплате зараде морају бити одређени општим актом послодавца, а законски рок као крајњи рок за исплату зараде за претходни месец је последњи дан текућег месеца, после кога послодавац не може на другачији начин да регулише исплату зарада.

Дужник који задоцни са испуњењем новчане обавезе, дугује поред главнице и затезну камату у смислу чл. 277. ЗОО. Када је главно потраживање исплаћено, обрачуната камата од дана доспелости, до дана исплате, као споредно потраживање, постаје главно потраживање, на који износ поверилац има право на процесну камату, сходно чл. 279. ЗОО.

Наиме, право на исплату камате због доцње дужника у исплати главног потраживања регулисана је Законом о облигационим односима, у чл. 277., којим је прописано је да дужник који задоцни са испуњењем новчане

обавезе дугује поред главнице и затезну камату, услед чега право на камату због доцње не зависи од признавања тог права од стране туженог, нити од тога да ли је иста уговорена, већ од чињеница да ли се ради о доспелој обавези и испуњењу обавезе на начин и у време како је предвиђено.

Одредбом чл. 295. ЗОО предвиђено је да обавеза престаје кад се испуни (ст. 1), а престанком обавезе гасе се јемство, залога и друга споредна потраживања (ст. 2). Исплатом главног потраживања, када обавеза престаје, гаси се и право на исплату камате, као споредног потраживања. Дакле, даном испуњења обавезе, ток камате се прекида, јер у конкретном случају споредно потраживање не може постојати без главног потраживања. Међутим, исплата главног новчаног потраживања у доцњи, не гаси ретроактивно право на исплату камате од доспелости и током трајања облигације до њеног престанка, јер се ради о доспелом, а неисплаћеном споредном потраживању.

С тим у вези одредбом чл. 279. ст. 1. ЗОО прописано је да на доспелу, а не исплаћену уговорену или затезну камату као и на друга доспела повремена доспела давања не тече затезна камата изузев кад је то законом предвиђено. На износ не исплаћене камате може се захтевати затезна камата само од дана када је суду поднет захтев за њену исплату (ст. 2).

Стога, како је главно потраживање исплаћено у доцњи, то је тужилац, као поверилац, стекао право да износ неисплаћене законске камате остварује као самостално потраживање у обрачунатом износу, од дана доспелости главног потраживања, до дана исплате, када се ток камате прекида, односно гаси споредно потраживање сходно чл. 295. ст. 2. ЗОО, са правом на процесну камату од дана када је суду поднет захтев за њену исплату сходно чл. 279. ст. 2. ЗОО. Из изнетих разлога нису основани наводи туженог којима се указује да је главни дуг исплаћен пре утужења, те да тиме што је тужена измирила своју обавезу, тужилац нема право на тражену камату у целини.

Из изнетих разлога нису основани ни наводи туженог изнети у поднесцима и на главној расправи, а којима се указује да је до доцње у исплати зарада дошло без кривице туженог, обзиром да у том правцу тужени не само да није доказао да је у време доспелости предузимао радње у циљу отклањања последица, већ ни на који начин није доказано да је у смислу чл. 121. Закона о раду, обавестио запосленог о разлозима неисплате, о че-

му је био дужан сходно ст. 3. истог члана, да достави обавештење уз обрачун зараде. Такође, нису основани наводи туженог којима се указује да уговором о раду и анексом уговора није прописана обавеза плаћања камате, обзиром да је доспелост главног потраживања, доцња дужника и право повериоца на исплату камате прописана законом. Осим тога, неосновано тужени у смислу оспоравања тужбеног захтева, истиче да је тужено предузеће државни поверилац, јер управља средствима у својини Републике Србије, те да с тим у вези отписује потраживања према привредним субјектима који су у поступку реструктурирања и приватизације. Тужилац је запослени код туженог, услед чега није привредни субјекат, већ лице који остварује своја права код послодавца, који је у обавези да према запосленом испуни сва потраживања која му гарантује радни однос. С тим у вези, изнети наводи не могу бити оправдавајући, јер послодавац планира средства за исплату зарада, сачињава програм и у складу са обезбеђеним и пренетим средствима треба да врши расподелу средстава и зарада.

У току поступка пред првостепеним судом тужени је истицао да се зарада код туженог регулисана Уредбом о висини зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 137/04) и Уредбом о начину и контроли исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 5/2006), а све у складу са Законом о јавним предузећима у обављању послова од општег интереса и Закона о приватизацији. Међутим изнети наводи не могу утицати на доношење другачије одлуке у овој правној ствари, обзиром да предмет захтева није исплата зараде која је регулисана наведеним прописима, већ исплата камате на исплаћену зараду у доцњи чија се основаност цени са становишта примене одредбе чл. 110. Закона о раду и Закона о облигационим односима.

Одредбом чл. 361. ст. 1. ЗОО, прописано је да застарелост почиње да тече првог дана када је поверилац имао право да захтева испуњење обавезе, ако законом за поједине случајеве није што друго прописано. Висина обрачунате камате за потраживања која су плаћена у доцњи, утврђује се у моменту исплате главног дуга у целисти, од када поверилац има право да захтева исплату тог потраживања и од када почиње да тече рок застарелости. У овој правној ствари тужба је поднета 29.01.2010. године, чиме је прекинут ток застарелости. Како се тужбеним захтевом потражује исплата камате због доцње у исплати зарада које се односе на период од 29.01.2007. године до јануара 2010. године, чија је доспелост наступала

месечно, у смислу чл. 110. Закона о раду, те како је у назначеном периоду тужени са закашњењем исплаћивао зараде, то несумњиво произилази да није протекао рок од три године, од дана настанка обавезе до дана када је тужилац захтевао испуњење сходно чл. 196. Закона о раду, услед чега није основан истакнут приговор застарелости потраживања.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, 18Гж1.2319/12 од 21.12.2012 године)

Аутор сентенце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу

УГОВОР О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ДИРЕКТОРА

(Члан 48. Закона о раду)

Уговор о раду закључен у смислу чл. 30. до 33., у вези чл. 48. ст. 1. Закона о раду и уговор о уређивању међусобних права, обавеза и одговорности закључен сходно чл. 48. ст. 4. Закона, као и уговор о уређивању међусобних права, обавеза и одговорности закључен сходно чл. 278. истог закона, су различити радно правни институти, обзиром да уговор о уређивању међусобних права, обавеза и одговорности, закључен у смислу чл. 48. ст. 4. Закона о раду, закључује лице које обавља послове директора ван радног односа, што је вид менаџерског уговора, чији садржај, у погледу уређења међусобних права, обавеза и одговорности, није предвиђен законом, као када је у питању уговор о раду, већ његов садржај уређују уговорне стране, осим у делу када је у питању накнада за рад, која има карактер зараде на коју се плаћају порези и сви доприноси за обавезно социјално осигурање, као и на зараду.

Из образложења:

Одредбом чл. 48. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005 и 61/2005) предвиђено је да директор може да заснује радни однос на неодређено или одређено време (ст. 1.), да се радни однос заснива уговором о раду (ст. 2.), те да радни однос на одређено време може да траје до истека рока на који је изабран директор, односно до његовог разрешења (ст. 3.). Међусобна

права, обавезе и одговорности директора који није засновао радни однос и послодавца уређују се уговором (ст. 4.). Лице које обавља послове директора из става 4. тог уговора има право на накнаду за рад која има карактер зараде и друга права, обавезе и одговорности у складу са уговором (ст. 5.). Уговор из става 2. и 4. овог члана са директором закључује у име послодавца управни одбор, а код послодавца код кога није образован управни одбор – орган који је одређен актом послодавца (ст. 6.).

Права директора после разрешења зависе од тога да ли је разрешен пре истека рока утврђеног уговором, као и од тога да ли је засновао радни однос на одређено или неодређено време, или је обављао посао директора без заснивања радног односа.

Уколико је директор засновао радни однос на неодређено време, по истеку мандата или у случају разрешења, он наставља радни однос на неодређено време код послодавца, на радном месту које одговара његовим квалификацијама и стручним способностима, што све треба да буде прецизирано и у самом уговору, односно све зависи од тога шта је уговорено, услед чега чињеница да ли је директор пре избора био у запослен код послодавца није релевантна.

С тим у вези, уколико послодавац не може да обезбеди одговарајуће радно место директору који је разрешен или му је престала функција, он остварује права као запослени за чијим радном је престала потреба, осим у случају када је разлог за разрешење истовестан разлогу за престанак радног односа, било да се ради о престанку радног односа по сили закона или у случајевима из чл. 175. Закона о раду, а нарочито у вези одредбе чл. 179. ст. 1. Закона о раду, којим су предвиђени факултативни отказни разлози.

Осим тога, сходно чл. 48. ст. 2. Закона о раду радни однос заснива се уговором о раду, који је у смислу чл. 30. истог закона, двострано обавезан и теретан уговор, јер ствара узајамне обавезе странака, дакле уговарају се права и обавезе које су унапред одређене. С тога, није само акт заснивања радног односа, већ и акт којим се уређују права, обавезе и одговорности, услед чега има и нормативно дејство, обзиром да одређује њихову садржину и закључује се у писменој форми, а сматра се закљученим када га потпишу запослени и овлашћено лице код послодавца, који моме-нат означава заснивање радног односа, а ступање на рад означава стицање

права и преузимање обавеза и одговорности из радног односа. Одредба чл. 33. Закона о раду, предвиђа садржину уговора о раду.

Уговор о раду закључује се пре ступања запосленог на рад и то у писаном облику сходно чл. 32. ст. 1. Закона о раду, али ако послодавац са запосленим не закључи уговор о раду у складу са ставом један, сходно ставу 2. исте одредбе, сматра се да је запослени засновао радни однос на неодређено време даном ступања на рад, како је предвиђао и раније важећи Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.70/2001 и 73/2001) у одредбама чл. 16. до 18.

Ова правна фикција релативизује писмени форму уговора о раду, јер омогућује да радни однос настане и без уговора о раду, обзиром да се ступањем на рад исказује воља и спремност послодавца да раднику омогући да ради, чиме се исказује обострана сагласност да се успостави радни однос. У случају да се на закључи уговор у писменој форми, запослени има право да пред надлежним, судом захтева утврђење да је радном односу, што не спречава, нити забрањује да запослени и послодавац, вансудски сагласношћу воља, закључењем уговора, регулишу радноправни статус запосленог од дана ступања на рад и за убудуће, тиме што ће на јасан и прецизан начин уговорити права и обавезе у складу са законом и општим актом.

Осим тога, уговор о раду закључен у смислу чл. 30. до 33. у вези чл. 48. ст. 1. Закона о раду и уговор о уређивању међусобних права, обавеза и одговорности закључен сходно чл. 48. ст. 4. Закона, као и уговор о уређивању међусобних права, обавеза и одговорности закључен сходно чл. 278. истог закона, су различити радно правни институти.

Наиме, уговор о уређивању међусобних права, обавеза и одговорности закључен сходно чл. 48. ст. 4. Закона о раду, закључује лице које обавља послове директора ван радног односа, то вид менаџерског уговора, чији садржај, у погледу уређења међусобних права, обавеза и одговорности, није предвиђен законом, као када је у питању уговор о раду, већ његов садржај уређују уговорне стране, осим у делу када је у питању накнада за рад, која има карактер зараде на коју се плаћају порези и сви доприноси за обавезно социјално осигурање, као и на зараду. С друге стране уговор закључен у смислу чл. 278. Закона о раду, закључују послодавац и запослени који је већ у радном односу, односно који је засновао радни од-

нос до дана ступања на снагу тог закона, а нема закључен уговор о раду, услед чега такав уговор треба да садржи елементе из чл. 33. ст. 1. Закона, осим из тач. 4. до. 8.

У конкретном случају, тужилац је након донете одлуке Скупштине Града Ниша број 06-93/2002-18 од 05.04.2002. године и именовања за директора туженика са мандатом од 4 године, ступио на рад, од када је, како произилази из списка, без закљученог уговора, остваривао права и обавезе из радног односа. Након разрешења, на основу одлуке Скупштине Града Ниша од 29.5.2006. године, поново је именован за директора Одлуком Скупштине Града Ниша бр.06-324/2006-6-15/02 од 29.05.2006. године, на основу које је наставио да ради ког туженог и у току трајања тог мандата закључен је Уговор о уређивању међусобних права, обавеза и одговорности број 01-1035/2 од 26.07.2007. године, применом чл. 33. и 278. Закона о раду. Међутим како назив уговора не опредељује правну природу уговора, то је првостепени суд пропустио да цени у складу са одредбама закљученог уговора на који начин је регулисан радно правни статус тужиоца, дакле да ли закључен у складу са одредбом чл. 48 ст. 1., 2. и 3., у вези чл. 30. до 33., Закона о раду или у складу са одредбом, става 4., исте одредбе, о чему ће у поновном поступку водити рачуна.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, 18Гж1.1677/12 од 15.10.2012. године)

Аутор сентенце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ НЕЗАКОНИТОГ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА

(Члан 191. став 2. Закона о раду)

Када је правоснажном пресудом кривичног суда запослени оглашен кривим и осуђен за кривично дело учињено у вези са радом, због радњи које формирају биће тог кривичног дела и због којих је у време престанка радног односа, покренут кривични поступак, а истовремено те радње представљају понашање којима је извршена повреда радних обавеза, тада се послодавац може ослободити од одговорности за штету, јер је запослени

својим поступцима проузроковао штету, за које је и оглашен кривично одговорним, услед чега је прекинута узрочно последична веза између акта о престанку радног односа који је поништен због мањкавости поступка у коме је донет и настале штете.

Из образложења:

За одлучивање о праву на накнаду штете због незаконитог отказа од значаја су околности и чињенице у погледу разлога због којих је дошло до престанка радног односа, као и разлога због којих је утврђена његова незаконитост, јер одсуство услова који се тиче узрочне везе између штетне радње-незаконитог отказа и штете, због околности која ту везу прекида, утичу на грађанско правну одговорност и остваривања права на накнаду, услед чега сама чињеница да је одлука о престанку радног односа поништена као незаконита, не подразумева по аутоматизму, обавезу послодавца да запосленом накнади штету на име изостале зараде.

Штета коју неко претрпи може бити последица не само туђег, него и властитог понашања у случају кад оштећени својим поступцима омогући другоме да му штету проузрокује или допринесе да буде већа него што би иначе била сходно чл. 192. ЗОО. Кривица оштећеног, у смислу грађанско правне одговорности, може бити разлог за искључење или умањење одговорности починиоца штете у зависности од удела једне и друге стране у проузроковању штете. Дакле у случају незаконитог престанка радног односа, утврђују се и цене општи услови за одговорност послодавца по основу кривице и то постојање штетне радње, а то је незаконити акт о престанку радног односа, постојање штете коју чини изгубљена зарада односно износ неостварене зараде и других примања, који опредељује висину штете, као и узрочно-последична веза.

Такође, послодавац се може ослободити од одговорности за штету уколико постоје околности на страни запосленог, која прекида узрочну везу између акта о престанку радног односа и проузроковане штете или уколико постоје околности које се односе на подељену одговорност у настајању штете.

У конкретном случају правоснажно је окончан поступак за оцену законитости одлуке послодавца о отказу уговора о раду тужиоцу, тако што је одлука поништена, обзиром да нису били испуњени услови за примену одредбе чл. 179. ст. 1. тач. 4. Закона о раду, јер је отказ уговора о раду заснован на оптужници Окружног јавног тужилаштва, Специјалног ту-

жилаштва у Београду Кт.С. 9/06 од 22.11.2006. године, а није донета прв-носнажна осуђујућа пресуда кривичног суда, што је било релевантно за оцену законитости одлуке о престанку радног односа и послодавцу је на-ложено да тужиоца врати на рад на послове који одговарају његовој стручној спреми, знању и способностима.

Међутим, како је правоснажном пресудом кривичног суда тужилац оглашен кривим и осуђен за кривично дело учињено у вези са радом, због радњи које формирају биће тог кривичног дела и због којих је у време престанка радног односа, покренут кривични поступак и подигнута наведена оптужница, а истовремено те радње представљају понашање којима је извршена повреда радних обавеза, то је несумњиво утврђено да је тужилац својим поступцима проузроковао штету, за које је и оглашен кривично одговораним, услед чега је прекинута узрочно последична веза. Тужбеним захтевом тражи се исплата накнада штете због изостале зараде за време док је тужилац био ван процеса рада, међутим без обзира што је отказ уговора о раду поништен због неправилности, односно због мањкавости поступка у коме је донет, произилази да се послодавцу не може приписати кривица за насталу штету, напротив за штету је одговоран искључиво тужилац, јер је она последица његовог понашања на раду и у вези са радом које има обележје кривичног дела, што је утврђено правоснажном кривичном пресудом и због чега је оглашен кривим и осуђен на казну затвора, па је стога без утицаја околност што у поступку који је провео послодавац није утврђивана тужиочева одговорност за повреду радне обавезе, односно акта недисциплине. Из изнетих разлога, како је тужени доказао да је штета настала без његове кривице, то нису испуњени услова за примену чл. 154. ст. 1. ЗОО и чл. 164. Закона о раду. У овој правној ствари цењени су и остали изведени докази, али су без утицаја обзиром да се односе на чињенице које су од значаја на висину штете.

Из изнетих разлога, Апелациони суд налази да тужбени захтев тужиоца није основан, па је сходно чл. 369. ЗПП одлучено о жалби и тужбеном захтеву као у изреци ове пресуде.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, 18Гж1 бр.1501/12 од 17.10.2012. године)

Аутор сентенце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу

МИРОВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА (Члан 79. Закона о раду)

Када запослени захтева да му мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада, услед наступања разлога одсуствовања са рада који су предвиђени у одредби чл. 79. ст. 1. тач. 1-5. Закона о раду, тада одлука послодавца има деклараторни карактер, јер само утврђује настало стање, уколико су испуњени законом предвиђени услови.

Из образложења:

Законом о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91...79/05) предвиђено је у одредбама чл. 15 до 19., да је установа правно лице, да су органи установе директор, управни и надзорни одбор, те да директора установе именује и разрешава оснивач, а да директор установе има права и дужности директора предузећа.

Према одредбама чл. 11. до 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/2000...119/12) који је био у примени у време насталог спорног односа, прописано је да су органи јавног предузећа управни одбор, директор и надзорни одбор, те да директора јавног предузећа именује и разрешава оснивач, да се оснивачким актом јавног предузећа утврђује мандат директора и да оснивач може до именовања директора јавног предузећа да именује вршиоца дужности директора, који ту функцију може обављати најдуже једну годину.

Законом о раду није уређено шта се сматра јавном функцијом, услед чега именовање на јавну функцију и значај јавне функције зависи од одредаба општег акта којим се уређује обављање те функције и с тим у вези именовање и постављење вршиоца дужности је требало бити регулисано нижим правним актом од закона, дакле статутом установе.

У конкретном случају Статутом Народног музеја који је био у примени у време доношења оспорене одлуке о престанку радног односа, није било предвиђено да је функција директора, јавна функција, без обзира на чињеницу да у складу са Законом о локалној самоуправи, надлежна Скупштина именује, односно бира директоре државних и друштвених предузећа и установа, као и вршиоце дужности директора.

Одредбама чл. 21. до 25. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12 од 17.12.2012. године), предвиђено је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом локалне самоуправе на период од 4 године, на основу спроведеног јавног конкурса, те да је директор јавног предузећа јавни функционер, у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција. Одредбом чл. 42. истог закона, прописано је да орган надлежан за именовање директора јавног предузећа из чл. 21. истог закона, именује вршиоца дужности директора у законом предвиђеним случајевима, те да вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћење директора. Дакле наведеним законом на сасвим другачији начин су предвиђени услови именовања директора јавних предузећа, са јасним одређењем да се ради о јавној функцији. Међутим, општим актом и ранијим законом, који је био у примени у време насталог спорног односа међу странка, није било предвиђено да је функција директора јавна функција, већ је дефинисан као орган управљања, услед чега се ни на који начин не може ни сматрати, да је именовање тужиоца од стране локалне самоуправе за вршиоца дужности директора, именоване на јавну функцију, како правилно закључује првостепени суд.

Одредбом чл. 79. Закона о раду предвиђено је да запосленом мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада, осим права и обавезе за који је законом, општим актом, односно уговором о раду другачије одређено, и наведена законска одредба одређује конкретне случајеве у тачкама 1. до 5. става 1. наведене одредбе, када запосленом услед одсуствовања са рада, мирује радни однос. Ван случајева предвиђених законом, који су децидивно прописани, послодавац може запосленом да утврди да му мирују права и обавезе, што зависи од околности случаја и воље и сагласности послодавца и запосленог.

У случају када запослени захтева да му мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада услед наступања разлога одсуствовања са рада који су законом предвиђени, тада одлука послодавца има деклараторни карактер, јер само утврђује настало стање, уколико су испуњени законом предвиђени услови.

У конкретном случају, тужилац је поднео захтев за мировање радног односа, услед именовања на јавну функцију чије вршење захтева да привремено престане да ради код послодавца, а у смислу чл. 79. ст. 1. тач.

4. Закона о раду. Правилно је првостепени суд ценио да у конкретном случају нису испуњени законом предвиђени услови да тужиоцу мирује радни однос, обзиром да се није радило о именовању на јавну функцију, па самим тим нису били испуњени услови ни за доношење деклараторног решења, односно нису били испуњени законом предвиђени услови да се утврди мировање радног односа, како се захтевом тражи.

С друге стране при чињеници да се не ради о јавној функцији, те да тиме нису наступили законски услови за мировање радног односа, и при чињеници да послодавац није одлучио о поднетом захтеву тужиоца да му мирује радни однос, послодавац је фактички донео негативну одлуку, услед чега је тужилац прихватио ризик одсуствовања са рада и последице на његов радно правни статус.

У таквој правној и чињеничној ситуацији, ступањем на рад у Народном музеју и заснивањем радног односа у тој установи закључењем уговор о раду у складу са одредбом чл. 48. Закона о раду, при том је без значаја чињеница да је заснован радни однос на одређено време, јер је такав радни однос потпуно изједначен у правима и обавезама, са радним односом на неодређено време, тужилац је заправо проузроковао доношење одлуке о престанку радног односа, обзиром да је засновао радни однос код другог послодавца. Како запослени не може бити у радном односу код два или више послодаваца истовремено, ван законом предвиђених случајева, то је правилан закључак првостепеног суда да тужбени захтев није основан.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, 18Гж1.506/13 од 05.04.2013. године)

Аутор сентенце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу

ДИСКРЕЦИОНО ПРАВО ДИРЕКТОРА

(Члан 130. Закона о основама система образовања
и васпитања „Сл. гласник РС“, бр. 72/09)

Коначна одлука директора школе о пријему кандидата у радни однос, треба да садржи оправдане разлоге давања приоритета изабраном кандидату, који гарантују да ће управо изабрани кандидат, најбо-

ље обављати послове радног места у интересу васпитно образовне делатности школе и при том се испуњеност услова тражених конкурсом, цени према чињеницама постојећим у моменту закључења конкурса.

Из образложења:

Правилно је првостепени суд ценио законитост оспорене одлуке са становишта примене одредбе чл. 120. до 130. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“, бр. 72/09), међутим, првостепени суд је пропустио да цени благовременост поднете тужбе о чему води рачуна по службеној дужности. С друге стране, оцена законитости коначне одлуке директора школе о пријему кандидата у радни однос од стране суда врши се судском провером правилности коришћења дискреционог права у интересу школе. Стога, ова одлука мора бити подобна за наведену оцену, те у том смислу да би била законита мора садржати оправдане разлоге давања приоритета изабраном кандидату који гарантују да ће управо изабрани кандидат најбоље обављати послове радног места у интересу васпитно образовне делатности школе и при том се испуњеност услова тражених конкурсом цени према чињеницама постојећим у моменту његовог закључења.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, 18Гж1. 1840/12 од 22.10.2012. године)

Аутор сентенце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу